

Introduction au droit et au vocabulaire juridique

Qu'est-ce que le droit?

A quoi sert le droit?

Comment le définir?

Il faut faire la différence entre le droit et les discours sur le droit. Nous allons commenter, discuter, donner des repères, donner une doctrine. Dans les discours sur le droit il faut faire une différence entre une approche théorique et une approche pratique. Approche théorique du droit se demander qu'est-ce droit de manière générale. Dans une approche pratique on va s'intéresser directement au droit en temps que textes ou de jurisprudences. Il va y avoir des approches plus spécifiques et concrètes dans des domaines bien définis.

Chapitre 1 La place du droit au sein de la société

1) Peut-il exister une société sans droit?

Nécessité du droit: Pourquoi le droit existe dans notre société?

Et pourquoi se développe-t-il de plus en plus (inflation législative). Il y a trop de droit. Dès qu'un problème se pose on y répond par le droit.

Nadège de la Rome antique **UBI SOCIETAS IBI IUS** —> « là où il y a une société il y a du droit ». Pour vivre ensemble il y a forcément des règles qui vont s'instaurer. Il va y avoir des règles écrites ou des règles coutumières. Le recours à la force nécessite des règles, le commerce et le troc également tout comme la propriété. **La première fonction du Droit et la pacification des rapports entre les individus.**

1-1) Droit pacifique tisse des rapports entre les individus

L'idée est que tous le monde soit soumis aux mêmes règles.

Thomas HOBBS auteur britannique du XVII^{ème} siècle connu pour son ouvrage *le Léviathan* 1651 ou *le citoyen* 1642

« L'homme est un loup pour l'Homme. » T.HOBBS. Alors que pour JJ Rousseau **L'homme est bon par nature, c'est la société qui va le pervertir.** Citation : « La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable » JJ Rousseau.

Pour HOBBS l'état de nature est une guerre permanente. Ces deux théories qui s'opposent sont les théories du contrat social. Pour HOBBS le droit va être une nécessité. Sert à protéger les faibles des forts en imposant les mêmes règles pour tous. Passage de l'état de nature à l'état de droit, cela va être qualifié de liberté, c'est grâce à l'instauration de ces règles que l'homme va être libre. **Léviathan = L'état.**

HOBBS considère qu'il faut un tiers qui va éditer les règles et qui va avoir le pouvoir de les faire respecter. Ce tiers est **l'Etat et pour le créer les Hommes doivent renoncer à une partie de la liberté qu'ils avaient.** Il faut renoncer à certaines libertés pour que l'état puisse assurer la sécurité. L'état devient souverain, il peut éditer les règles et les faire respecter y compris par la violence. **Pour HOBBS on échange la liberté contre la sécurité.**

Il va y avoir des droits inaliénables qui ne peuvent être données à l'état. **Le principal d'entre eux est le droit de résistance.** Le droit qu'on les hommes par nature de se protéger lorsque personne d'autre ne peut le faire est un droit que l'on ne peut abandonner par convention. Si le souverain viol ce droit, le contrat est annulé et nous nous retrouverions dans l'état de nature. Lorsque l'état n'est plus capable de me protéger, je redeviens mon propre protecteur. Le droit est un instrument de pacification qui est nécessaire au sein de la société.

1-2) Le droit un instrument de limitation du pouvoir du gouvernement

Comment protéger les gouvernés des gouvernements. C'est le rôle de la constitution. Le président élu est contraint de respecter la constitution. Le principe retenu, séparation des pouvoirs. On voit son origine dans l'histoire constitutionnelle Britannique.

Montesquieu philosophe du XVIII^{ème} siècle, ouvrage: *L'esprit des lois* « pour que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir. »

Pouvoir législatif (fait les lois), pouvoir exécutif (celui qui applique les lois), pouvoir judiciaire (règle les litiges). Il faut créer différentes institutions pour segmenter le pouvoir pour ne pas qu'il sorte du cadre qu'on leur a fixé. Toutes les institutions ont le pouvoir de bloquer les autres institutions. DDHC article 16: Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. DDHC seconde moitié du XX^{ème} siècle qui garantit les droits. Avec la création de juridiction constitutionnelle. Leurs buts est de contrôler que les lois sont conformes à la constitution.

France 1958 création du Conseil Constitutionnel. Qui est la première institution juridictionnelle. **Il faut attendre 1971 pour que cette juridiction soit contraignante au Parlement.**

Le but étant d'obliger le gouvernement de respecter les droits des individus.

Le droit est nécessaire dans une société pour pacifier les relations entre les individus et pour limiter le pouvoir des gouvernants dans le but de garantir la liberté des individus.

2) Théories du droit naturel

2-1) définitions générales des théories du droit naturel

Le point commun entre ces théories est qu'il existe quelque chose au-dessus du droit dans la société en vigueur a un instant t. Ce qui est au-dessus du droit peut-être un idéal de justice, des valeurs, des principes non écrits, des coutumes. La loi des Hommes produite par la société ne doit pas être supérieure au droit en vigueur, il y a une justification à la désobéissance aux lois en vigueur. Voir Antigone, elle résiste face a son oncle pour offrir une sépulture à son frère. Distingue la loi des hommes a celle de la nature. Celle de la nature sont supérieures.

2-2) Les théories du droit naturel a travers l'histoire

2-2-1) Le droit naturel classique dans l'antiquité: la primauté de l'ordre naturel des choses

Aristote considère qu'il y a un droit naturel non écrit qui va résulter non pas de la volonté des hommes mais de la nature des choses. Le droit doit être conforme a l'ordre naturel qui gouverne les êtres et les choses. Aristote développe une philosophie réaliste ou pragmatique, il regarde la réalité pour définir les lois naturelles. L'univers tant vers l'ordre et l'équilibre.

EX: si un citoyen prête de l'argent à un autre on s'attend à ce que l'autre le rembourse.

Pour Aristote l'Homme est animal social. Il y a donc forcément des règles. Les lois naturels vont préexister et les hommes vont essayer de les retransmettre par écrit. Aristote pense que les lois naturelles peuvent évoluer en fonction de la société. Pour découvrir ces lois naturels, l'Homme doit utiliser sa raison.

Les lois naturels préexistent a la bonté humaine et peuvent être observées et retranscrites en droit commun.

2-2-2) Droit naturel au moyen âge. Théologien du XIIIème siècle St Thomas AQUIN principal auteur de la scolastique philosophique enseigner dans les universités au moyen âge. Ouvrage: La somme des théologies 1266-1274. Il identifie plusieurs types de lois:

-1ere Loi humaine, les lois créées et en vigueur à un instant T.

-2eme les Lois naturels, il faut être conforme a la nature des choses, pour les découvrir l'homme fait appel a sa raison et en observant la société.

-3eme Lois divines (ancien et nouveau testament). Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et la raison, entre la foi catholique et la raison humaine. Pour lui il ne peut y avoir de contradiction entre la foi catholique et la raison humaine, entre la théologie et philosophie. L'homme tente de respecter les lois naturels et à travers cela tendre vers le divin.

2-2-3) Droit naturel moderne: le droit inhérents et sacrée de l'homme

L'auteur Hugo GROTIUS, Hollandais, XVIIème siècle son ouvrage principal traite sur le droit de la guerre et de la paix.

Selon lui, le droit naturel ne découle pas nature des choses comme pour Aristote. Ni de la création divine. Pour lui le droit naturel va découler de la nature de l'Homme. Le droit naturel est indépendant de l'ordre divin. Il considère qu'il y a une autonomie du droit naturel. H Grotius considère que l'homme est au centre de tout. L'homme devient maître de la création il devient le point central. Ce qui rapproche des philosophes des lumières = DDHC les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Aujourd'hui toutes les sociétés modernes donnent des droits. (Préambule DDDH: idée que la représentation des peuples français constituer en assemble nationale considérant l'ignorance, mépris des droits de l'homme sont les seules causes de la corruption des gouvernements.)

Volonté de concrétiser la DDHC.

Préambule d'article: précédé un texte, proclamation de valeur, mais n'as cependant pas de valeur juridique.

2-3) Critiques des théories du droit naturel

-1ere critique, manque de rigueur scientifique de ces théories. Comment on détermine qui identifie ces lois naturels.

Aujourd'hui on compare les droit commun entre les pays pour en tirer un droit supérieur.

-2eme critique, dimension morale des théories du droit naturel. Théories du droit naturel vont imposer des valeurs. Certains auteurs pensent que c'est anti-démocratique, car la démocratie repose sur le choix de la majorité et le relativisme des valeurs. Relativisme des valeurs car une majorité peut pendre des décisions qui peut être changer par une autre majorité quelques temps après.

-3eme critique, si on considère que l'homme est maître de la nature alors il n'y a plus de place pour la nature (végétation).

Les droits inaliénables et sacrées sont incompatibles aux libertés individuelles. Si on interdit les voyages, les entreprises qui polluent... Alors on réduits les libertés des particuliers et entreprises. Il faut trouver un équilibre entre la liberté des individu et la préservation/protection des ressources. Car sinon l'homme s'auto détruit.

Existe t-il quelque chose au-dessus du droit/principes supérieurs? (Théorie du droit naturel?)

3) Théorie positivistes du droit, le droit comme réceptacle des valeurs d'une société.

Nous ne parlons pas de positivisme dans le sens d'un jugement de valeurs. Positivisme fait référence au droit en vigueur, droit qui est applicable. Le droit c'est ce que décide les hommes à un instant donné.

3-1) Définition générale :

Ces théories positivistes se sont construite en réaction des théorie du droit naturel. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas

d'ordre supérieur. Le droit c'est les règles posés par les hommes dans une société donnée. Observation du droit tel qu'il est et non du droit qu'il devrait être. Derrière cette idée, il y a aussi un objectif scientifique de ces théories positivistes. Volonté de savoir comment elles (théories positivistes) sont déterminées ?

Il y a une volonté de s'ancrer dans le réel. Volonté de vouloir séparer droit de la morale. Il y a un total relativisme des valeurs. Dans une démocratie la majorité de prendre telle décision. Distinction entre droit et morale importante. La morale c'est amener un individu à s'épanouir individuellement. Le droit a une finalité beaucoup plus large. Il vise à régir les relations entre tous les membres d'une société.

Question de la sanction ?

Dans la morale la sanction est plutôt psychologique. Dans le droit la sanction vient d'une institution. Idée de contrainte dans le droit que l'on ne retrouve pas dans la morale. Distinction entre les règles morales peuvent être relativiser, quand on fait des lois on prend aussi en compte notre époque (on prend en compte la morale de l'époque).

Il y a toujours une évolution de la société puis vient ensuite le droit qui se penche sur cette évolution. Le droit est toujours en retard sur l'évolution de la société. Le droit est un reflet des valeurs à un instant T. Dans le droit il y a pleins de références qui ont une connotation morale. Ex: la bonne foi, Art 1104 CC « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Art 6 CC fait référence aux bonnes mœurs. « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Jusqu'au 1994 ou on a refait le code pénal, refonte du code pénal, il existait un délit d'atteinte aux bonnes mœurs. Ancien code pénal art 284 « quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ». Règles d'éthique et de déontologie à destination des gouvernants et des professionnels.

Ex: relation médecin/patient, avocat/client...

Il apparaît que l'on essaye de mettre une dimension morale au sein des relations professionnelles.

Les auteurs qui ont une visée scientifique ne nient pas qu'il y a de la morale dans le droit. Cependant leur objet d'étude est exclusivement le droit positif. Ils s'intéressent au droit dès que ce dernier est en vigueur. Ils veulent trouver une autonomie du droit.

3-2) Variantes

Les distinctions entre les différentes théories positivistes du droit.

Il y a trois théories :

- Positivisme étatique

On assimile le droit aux règles de droit produites par l'état. Toutes lois produites par l'état doivent être respectées, peu importe si elle est juste ou injuste.

Auteurs :

-Nicolas Machiavel XVI siècle - le prince, porte sur la fondation de l'état, comment gouverner.

-Thomas Hobbes - le Léviathan, souveraineté de l'état, formation de l'état.

Ces deux auteurs considèrent que le droit est un phénomène exclusivement étatique, l'état est le souverain. L'état n'a pas de limite, il dicte les lois qu'il veut. Peu importe si c'est juste.

Pour les auteurs « L'intention du législateur est toujours supposée conforme à l'équité ». Le juge est simplement là pour appliquer la loi.

On arrive au XIX siècle, théorie allemande va aussi retenir une théorie positiviste du droit, pour faire table rase de ce qu'avait fait les théories du droit naturel avant. Et de la même manière le droit est uniquement d'origine étatique.

-Hegel, identifie le droit à l'état. « Tout ce qui est étatique et juridique et tout ce qui est juridique est étatique ».

-Maurice Hauriou, s'intéresse aux institutions « ce sont les institutions qui font les règles de droit, ce ne sont pas les règles de droit qui font les institutions ».

-Rémond Carré de Malberg (auteur français) - contribution à la théorie générale juridique de l'état, il induit la théorie de l'autolimitation de l'état. L'état est souverain car il accepte de s'imposer certaines limites. Cette théorie de l'autolimitation est toujours en vigueur. Pour eux le champ du droit se limite aux règles établies par l'état.

- Le normativisme (théorie dominante aujourd'hui)

Hans Kelsen - théorie pure du droit, théorie positiviste la plus radicale. Pour lui il faut analyser le droit en dehors de tous les autres éléments (la morale, les approches historiques, sociologiques...). Il s'agit d'une ambition scientifique. Idée d'autonomisme le droit par rapport aux autres sciences. Théorie de Kelsen, c'est que le fondement du droit est le droit lui-même. Il y a toujours une norme qui va former une autre norme, idée pyramidale/hierarchies des normes. Art 45 constitution. Le droit produit du droit. Conseil constitutionnel contrôle que les lois soient conformes à la constitution. Il faut un point de départ (la constitution).

Qui a-t-il au-dessus de la constitution ?

Son postulat est qu'il y a une norme hypothétique fondamentale. Il appelle ça Grundnorm.

- Positivisme sociologique

On va aller voir concrètement comment sont produites les normes. Cette théorie rejette l'idée d'un droit supérieur, et elle rejette également le fait que le droit soit uniquement étatique. Pour cet auteur le droit positif est légitime car il est le reflet du milieu social et des normes d'une société.

Savigny, pour lui la source du droit est essentiellement populaire et historique. C'est la coutume. Le droit positif est là pour

normaliser la coutume.

Léon du Guy, va chercher la justification du droit dans la société sociale. Différence avec Aristote est que pour Aristote il y a des lois naturels qui préexistent, alors que pour eux cela n'as pas lieux. Comment les règles se créent en dehors de la coutume. La violation de certaines règles vont donner des sanctions, qui vont être rédigés en normes juridiques contraignante.

Le droit est issu des comportements sociaux qui érigés en normes de droit.

La théorie est scientifiquement logique.

3-3 Critiques des théories positivistes du droit

L'idée générale est qu'il y a pas de valeur au-dessus du droit. La conséquence de cette idée est qu'elle légitimiste toutes les lois qui peuvent être promulgués, même les plus totalitaires. Il y a eu un débat après la chute du régime nazi pour savoir est-ce que le droit nazi est du droit?

La réponse dépend du fait que si l'on est partisans du droit naturel alors non, va à l'encontre de toutes les valeurs morales modernes. Mais dans la théorie positiviste oui, car ils ont suivi les mêmes procédures qui suivent une procédure.

Karl Schmit défend les lois nazis.

Auteur contemporain Zarka écrit un ouvrage en 2005 « un détail nazi dans la pensée de Karl Schit » il met en évidence la pensée de Karl schmit. Il tente de justifié les pires lois du nazisme et arrive même à accrédité les procédures et le fonctionnement des ces lois en les rendants acceptables.

Les théories positivismes du droit en se mettant uniquement sur le droit en vigueur, le risque est de légitimer indirectement les lois qui porteraient atteintes aux droits et libertés, puisque la question du juste est séparer du droit.

Chapitre 2: Définir le droit

Def: « droit est un ensemble de règles de conduites assorti d'une sanction contraignante dont l'incarnation la plus évidente se trouve dans la loi ». Il y a eu des évolutions ces dernières décennies qui échappent à cette définition.

Les théories réalistes du droits. Ils s'écartent du fait que le droit c'est la loi. Ils vont s'en remettent au juge. On se rapproche de la pratique, il faut voir comment le texte est mis en œuvre. Ils pointent la marge de manœuvre dont le juge dispose pour interpréter le droit. Les théoriciens démontrent que les juges peuvent interpréter et créer du droit.

1) Les critères de définition de la règle de droit

La fonction première du droit est de réglementer les comportements humains. Il faut définir ce qui est interdit de ce qui ne l'est pas. Les critères:

1-1) Le caractère prescriptif de la règle de droit

Une règle de droit a un caractère prescriptif, il a pour objectif d'obtenir un comportement. Un énoncé descriptif, qui se contente de décrire. Dans un énoncé prescriptif, il est décrit un comportement souhaité, ce qui doit être. Ex: les automobilistes roulent à 140 au lieu de 130 (descriptif). Il ne faut pas rouler à plus de 130 sur l'autoroute (prescriptif). L'énoncé prescriptif ne peut pas être faux. Il n'y a pas d'énoncer prescriptif peut-être vrai ou faux. Ex: autoroute on dit qu'il est interdit de rouler a plus de 130 est que statistiquement tous le monde est a 140, cela ne veux pas dire que l'interdiction est fausse, elle n'est juste pas respecter. L'énoncer prescriptif est bon. Si on dit d'un point de vue descriptif les gens roulent à 140 et que statistiquement les gens roulent à 130. La on peux dire que c'est faux.

Il y a plusieurs formes d'énoncés prescriptifs:

-L'interdiction, il n'y a pas d'alternative, c'est une interdiction assortie d'une sanction. Ex: pas le droit de rouler à plus de 130

-Obligation, obliger un certain comportement. Ex: un automobiliste doit s'arrêter au feux rouge

-Prescriptif, il autorise un comportement. Il y a une alternative car on est pas obligé de suivre l'obligation. Ex: il est permis de fumer dans tel ou tel zone. Pas d'obligation de fumer

-L'habilitation. L'habilitation à des conséquences juridiques. Ex: le Conseil Constitutionnel est habilité à contrôler les lois

1-2) Le caractère général et impersonnel de la règle de droit

Ce principe à été consacre en 1789, abolir les privilèges des anciennes classes de l'ancien régime. Art 6 déclaration « La loi doit être la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punisse ». Le caractère général et impersonnel est dans l'idée que la loi ne vise pas un individu ou un groupe d'individus en particulier. Il faut la formuler de façon abstraite pour à elle puisse touche l'ensemble de la population. La finalité de ce caractère est de garantir l'égalité de tous devant la loi.

Cependant certaines lois peuvent viser un groupe de personnes (lois pour les propriétaires de droit immobilier). Il y a une distinction entre le droit civil et le droit spécial. Le droit commun est l'idée de prendre une règle qui puisse s'appliquer à un maximum de personne. Art 1101 CC « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ce dernier définit ce qu'est un contrat, il vaut pour tous les contrats.

Quand le droit spécial interroge le droit commun, c'est le droit spécial qui prévaut. Le droit spécial est celui qui vise les

particuliers.

Pour résumer, l'idée est de garantir l'égalité de tous devant la loi lorsque l'on ne viole pas une situation en particulier.

1-3) Le caractère permanent de la règle de droit

Le principe est de garantir l'égalité de tous devant la loi. Pour ça il faut que la règle de droit est une certaine permanence/stabilité. La loi va toujours s'appliquer même quand ceux qui l'on rédigé ont terminés leur mandat. La loi continu à s'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit abrogée.

Abrogation c'est l'idée que la loi arrête de produire des effets juridiques au moment de son abrogation.

Y a-t-il une rétroactivité. Une fois que l'on abroge une loi cela vaut pour l'avenir mais pas pour les situations passées.

La règle de droit a un caractère permanent mais elle n'est pas immuable. Il est possible à tous moments pour les autorités compétentes de modifier ou d'abroger une loi lorsque cela est nécessaire.

La loi est applicable du moment où elle entre en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. Pendant ce laps de temps la loi est applicable à tous.

La sécurité juridique est le fait que le droit doit être prévisible. Il faut que les individus à qui s'applique les lois puissent savoir que tel ou tel comportement puisse avoir des conséquences et quelles sanctions ils peuvent craindre.

On peut imaginer des dérogations de la loi, dispositions transitoires : entre l'abrogation et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les individus savent que la loi est applicable et pendant combien de temps (sécurité juridique). Ex: la loi est abrogée mais en attendant la nouvelle loi il faut mettre en vigueur une loi transitoire.

Les règles de droit sont prescriptibles, générales, impersonnelles, permanentes et elles ont un caractère contraignant assorti d'une sanction.

1-4) Le caractère contraignant de la règle de droit

Il y a une sanction en cas de violation de la règle de droit par l'état. Car selon Weber « l'état dispose du monopole de la violence légitime ». Ce principe interdit la vengeance privée par la vengeance. L'état crée ses sanctions non dans un intérêt particulier, mais dans l'intérêt général, ce qui le rend légitime. Dans les fonctions de règles de droit il y a des personnes habilitées à prendre des sanctions, souvent le juge.

Le droit à évoluer vers plus de souplesse, ces normes sont moins contraignantes. Soft law (droit souple) règles moins contraignantes, elles ont pour but une recommandation et non une sanction. Les soft laws veulent un comportement particulier. Souvent ces soft laws interviennent avant les lois contraignantes. Ex: ONG, ces ONG ne peuvent pas contraindre les états elles peuvent donner des recommandations, et inciter les états à suivre ces recommandations. Cependant en classant les états et en rendant ces classements publics, les ONG peuvent inciter les pays à se soumettre aux recommandations. Au risque qu'ils soient mis de coter sur le point de vue international.

2) L'interprétation de la règle de droit

Cette interprétation est évidemment nécessaire à cause du caractère général et impersonnel de la règle de droit. Il va falloir adapter cette règle générale et impersonnelle à un cas particulier. Cette action d'interprétation est le rôle du juriste.

C'est un élément indispensable car un même texte peut avoir plusieurs interprétations différentes.

Philosophe américain du droit Herbert Hart développe une théorie sur le fait que le droit est une texture ouverte, il y a toujours une incertitude qui perdure. Revirement de jurisprudence est le fait de dire on change de décision/ on retient une autre interprétation vis-à-vis d'une jurisprudence. On considère que lorsque le texte est clair il n'y a pas besoin d'interprétation. C'est seulement quand le législateur a mal fait son travail que le juge doit interpréter. Si le juge est incapable de trancher c'est un déni de justice. Art 4 CC « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte de silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice ». Le juge est obligé de trancher pour une décision. Deux textes contradictoires peuvent être applicables pour un même cas. Le juge va devoir choisir quel texte s'applique, y compris pour les situations nouvelles. Ex: DDHC 1789 qui est compris dans le bloc de constitutionnalité de la constitution. La liberté d'expression de 1789 n'a rien avoir avec les réseaux sociaux. Pour autant il faut trouver une interprétation qui puisse s'appliquer sur l'ensemble du territoire.

Le système juridictionnel est hiérarchisé. Première instance on va devant le juge, si on est condamné. On peut faire appel, on demande à un autre juge de réexaminer le cas et de donner une décision. Si on perd encore on peut aller en cassation pour que l'interprétation constante puisse être rendue. Il y a le conseil d'état pour l'administratif et la cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Tous les juges inférieurs à cette hiérarchie doivent appliquer la décision de la cour de cassation.

2-1) La distinction entre l'interprétation authentique et l'interprétation doctrinale.

Il peut y avoir plusieurs interprètes d'un même texte. Selon qui interprète le texte, l'interprétation n'aura pas la même valeur. L'interprétation authentique est faite par un organe d'interprétation du droit qui est habilité à faire cette interprétation. Le plus souvent c'est le juge qui est habilité à interpréter le droit. L'article 61 de la Constitution donne la compétence au CC pour contrôler la conformité d'une loi à la Constitution. Il en découle que l'interprétation authentique du juge va avoir des effets juridiques contraignants. Il peut y avoir d'autres interprètes authentiques. Si l'on regarde attentivement la

Constitution, le Président de la République est aussi un interprète authentique de la Constitution (article 5). Si tous les juges ont une interprétation authentique et que diverses interprétations d'un même texte se côtoient, il arrive que des interprétations se contredisent. Pour régler ce problème, on utilise la hiérarchie des juridictions. C'est l'interprétation de la juridiction la plus haute dans la hiérarchie qui prime. C'est ainsi afin de garantir la sécurité et la prévisibilité juridique.

L'autre interprétation possible des textes est l'interprétation doctrinale. Ce que l'on appelle la doctrine est la production des chercheurs et des commentateurs des textes de droit. La différence entre ces interprétations et les interprétations authentiques est que ces auteurs ne sont pas habilités à interpréter et par conséquent leurs interprétations n'entraînent aucune conséquence juridique. Le seul pouvoir de cette interprétation est d'influencer celle des personnes habilitées.

2-2) L'interprétation conforme à l'intention de l'auteur.

Si l'on retient cette approche, l'interprétation serait avant tout un acte de connaissance de l'intention de celui qui écrit le texte de loi. Cela signifie que l'on va considérer qu'il y a un sens préexistant au sein du texte et qu'il suffit de le découvrir. Au lendemain de la Révolution, il y avait des référés législatifs. Ces référés législatifs servaient à ce que les tribunaux demandent au Parlement l'interprétation à retenir d'une loi. Le juge a donc un rôle très mineur à cette époque. Cette idée domine pendant tout le XIX^{ème} siècle à travers l'école de l'exégèse. Cette école s'est développée à la suite de l'entrée en vigueur du Code civil. Cette école veut que l'on se focalise sur le texte et l'intention de l'auteur uniquement. Parfois le texte ne suffit pas. La technique d'interprétation qui rentre dans cette idée générale est appelée interprétation historique du texte. Il faut alors aller chercher dans les documents historiques quelle était l'intention de l'auteur. Michel Troper parle d'interprétation génétique, c'est-à-dire de remonter au moment de sa création. C'est une technique que l'on retrouve beaucoup pour l'interprétation des constitutions. Les constitutions sont rédigées avec des termes très généraux et il faut donc remonter à l'intention des rédacteurs des articles pour savoir quoi faire. On se rend compte que l'interprétation actuelle de la Constitution est très éloignée des volontés des auteurs de l'époque.

On perçoit facilement les limites de cette interprétation. Plus le texte est ancien, moins la volonté des auteurs de l'époque a d'intérêt aujourd'hui. Par exemple, la DDHC a toujours une valeur constitutionnelle et peut être appliquée. Mais l'interprétation génétique de ce texte n'a aucun intérêt puisque les questions de l'époque et celles d'aujourd'hui sont très différentes. Ce type d'interprétation est donc très marginalisée de nos jours.

Pour résumer, l'idée est que l'interprétation est la découverte du sens que le législateur a voulu donner au texte. Cela signifie qu'il y aurait un sens préexistant. On donne donc un rôle beaucoup plus important à l'auteur qu'à l'interprète. Le juge est là pour révéler et pas pour créer.

2-3) L'interprétation constructive du juge au moment de l'application.

Une idée s'est développée au XX^{ème} siècle en réaction à l'idée de l'école de l'exégèse. Cette idée dit qu'il est illusoire, voire hypocrite, de penser que le législateur ait pu penser que sa loi puisse s'adapter à toutes les situations. Il ne suffit pas de rechercher une intention de l'auteur. Il faut plutôt se poser la question du sens du texte. C'est l'école réaliste de l'interprétation du droit. Cette école s'est développée aux EU. Les membres de cette école mettent en avant qu'un texte est porteur de plusieurs interprétations possibles. Les énoncés sont donc par nature indéterminés. C'est l'interprète qui donne un sens au texte, et sans celui-ci, le texte n'a pas de sens. Certains pensent même qu'une loi ne devient une norme juridique qu'après avoir été interprétée par un juge. Ce qui est mis en évidence par cette vision du droit est que le droit est vivant et qu'une même loi peut voir son interprétation évoluer sans modification du texte.

En France, François Gény est un auteur important sur le sujet. Il a développé une méthode qu'il appelle la méthode de la libre recherche scientifique. Il reconnaît que l'interprète a la liberté de rechercher les solutions qui peuvent l'aider à trancher le cas qui lui est soumis. Cette liberté d'interprétation reste présente même s'il doit aller au-delà du texte. Pour Gény, il existe certaines limites à imposer au juge comme la défense de l'intérêt collectif. Quand le juge s'écarte du texte, on attend de lui qu'il justifie cet écart. Par exemple, la décision « Liberté d'association » du CConst de 1971. La liberté d'association n'apparaît nulle part dans la Constitution et donc la liberté d'association a été garantie grâce à une interprétation hors-texte de la Constitution. Le fait de consacrer la liberté d'association de manière constitutionnelle fait que le législateur ne peut plus la restreindre. Le CC a utilisé le préambule de la Constitution de 1958 pour justifier une telle décision alors que ce texte n'avait pas de valeur juridique. Après cette décision, le CC va intégrer ce texte et d'autres au bloc de constitutionnalité et ces textes vont donc entrer dans sa juridiction. D'un point de vue juridique, il est assez douteux qu'un juge décide de donner une valeur constitutionnelle à un texte sans que le pouvoir représentatif n'intervienne. En termes de création de pouvoir d'interprétation, cette situation est allée très loin. La logique de François Gény est que cette décision était nécessaire pour s'adapter aux volontés de la société.

Il y a aussi ce que l'on appelle les réserves d'interprétations. Le CConst contrôle une loi et la considère contraire à la Constitution. Pour autant il ne censure pas la loi mais dit qu'elle n'est conforme que sous réserve d'être interprétée d'une certaine manière. Il existe trois types de réserves d'interprétations. La première est neutralisante : le juge écarte les interprétations non-constitutionnelles. Il y a ensuite la réserve d'interprétation directive : le juge désigne l'interprétation à retenir. Enfin, la plus critiquée est la réserve d'interprétation constructive : le juge va ajouter au texte des termes pour le

rendre conforme à la Constitution.

La critique du gouvernement des juges est principalement réalisée par *Edouard Lambert* qui se base sur l'analyse de la Cour Suprême américaine. Pour lui, le juge n'est là que pour appliquer la loi et le CConst ne doit pas modifier les lois mais juste dire qu'elles ne sont pas constitutionnelles. La critique du gouvernement des juges se focalise sur la légitimité de personnes non-élues pour prendre des décisions qui engagent la société.

Pour autant, certains auteurs ont montré qu'il ne fallait pas être aussi radical et qu'en réalité le juge ne crée pas de droit. Le gouvernement des juges est généralement une critique faite par des gens très conservateurs au niveau de la loi. *Michel Troper* a créé une théorie des contraintes. La théorie des contraintes est que quand le juge fait son interprétation, il est contraint par tout un tas d'éléments. Notamment parce que le juge doit se baser sur un texte pour rendre une décision. Il ne peut pas inventer un texte et donc ne crée pas de droit. Le juge a des contraintes textuelles mais aussi procédurales. Il doit être saisi pour se prononcer. Il ne peut pas s'auto-saisir. En plus de ça, il doit justifier ses arguments par du droit. Ainsi, ils ne peuvent pas exprimer ouvertement leurs positions politiques. Enfin, il y a aussi des contraintes de faits (origine sociale, position politique, formation de droit, etc.).

Pour résumer, l'idée est que l'interprétation est au moins aussi, voire plus, importante que le texte. La norme juridique est le texte interprété. Il y a aussi une distinction à faire entre interprétation authentique et doctrinale. Seules les décisions de juge sont contraignantes juridiquement. La dernière distinction est celle à faire entre l'intention de l'auteur et l'interprétation personnelle du juge.

Chapitre 3 : la classification des droits.

1) La classification des principaux modèles en droit comparé.

Qu'est-ce que le droit comparé ?

C'est une entreprise assez complexe de faire du droit comparé. Cela nécessite une méthodologie particulière. Le but du droit comparé est d'identifier des traits ou caractéristiques communs dans différents modèles de droit. Il faut donc faire ces modèles au préalable. Des auteurs qui analysent le droit dans différents pays vont essayer de les comparer.

Cette pratique existe depuis l'Antiquité. On y a retrouvé des textes où les cités s'intéressaient au droit des cités voisines pour voir comment il fonctionnait. Un des objectifs du droit comparé est d'améliorer son propre droit.

En France, c'est sous le Second Empire, en 1869, que l'on va créer la Société de Législation Comparée (SLC). L'intérêt de regarder le droit dans d'autres sociétés est de comprendre cette société. Le droit est le reflet des valeurs d'une société. Pour comprendre une société, regarder son droit nous donne une idée des valeurs et du fonctionnement de celle-ci. De nos jours, cependant, il y a une harmonisation et une uniformisation du droit dans le monde, principalement dans le monde occidental.

En France, le professeur *Esmein*, résumait le droit comparé de cette manière : « Il faut classer les législations des différents peuples en les ramenant à un petit nombre de familles ou de groupes dont chacun représente un système de droit original. » Éléments de droit constitutionnel français et comparé.

De nombreuses questions d'ordre méthodologique se posent. On peut faire une macro-comparaison et s'intéresser aux grands modèles et aux traditions juridiques. On tire des modèles généraux de plusieurs états. Un autre modèle est celui de la micro-comparaison, où l'on prend quelques états en analysant des points précis. Il n'y a pas de méthodologie meilleure qu'une autre, le choix de la bonne méthode dépend de ce que l'on cherche à observer. De nos jours, cependant, l'harmonisation du droit rend la méthode de macro-comparaison plutôt obsolète.

1-1) Le modèle de droit romano-germanique.

L'expression de droit continental est aussi utilisée pour désigner le droit romano-germanique. Ce modèle s'est formé depuis le XII^{ème} siècle en Europe. Il s'est formé avant tout dans les grandes universités européennes. C'est une question doctrinale. La référence au terme romano-germanique se fait en référence au Saint Empire Romano-Germanique (SERG) qui a existé en Europe du X^{ème} au XIX^{ème} siècle et qui réunissait plusieurs parties de l'Europe occidentale. Cet empire se voulait comme étant la continuité de l'Empire romain d'occident. L'idée est que le droit romano-germanique est l'héritage du droit romain. Dans les théories du droit naturel, *St Thomas d'Aquin* voulait faire la jonction entre la théorie d'Aristote et le droit canonique catholique. Il y avait donc cette idée que l'étude du droit romain était la meilleure formation intellectuelle possible car les Romains sont les premiers à avoir systématiser le droit en créant des Codes. Par exemple, en 529, le Codex est créé. Le Codex est un rassemblement de la législation impériale dans toutes les matières. En 533, le Digeste est créé. Ce texte rassemble l'ensemble des opinions des grands juristes de l'époque. Cela correspond au droit positif et à la doctrine. Cette tradition a donc toujours une influence déterminante sur la façon dont on fabrique le droit aujourd'hui. En 533, les Institutes sont également créées. On y trouve les définitions des concepts fondamentaux du droit, qui vont

structurer le droit civil en plusieurs catégories. Il s'agit du premier manuel de droit.

Ce qui est important pour la traduction romano-germanique est la redécouverte de ces textes qui se fait au X^{ème} siècle. Ce droit va être redécouvert sous le SERG et les juristes vont vouloir en imprégner leur culture juridique. Les auteurs du MA étaient appelés les glossateurs. Gloser signifie détailler un texte ou une idée dans ses moindres détails. A l'échelle d'un empire, une tradition a été créée et cette culture juridique a été diffusée dans l'ensemble du SERG.

Le principal trait commun retrouvé dans le modèle RG est que la tradition juridique RG est le droit écrit et la codification. La codification est la systématisation du droit. Au XIX^{ème} et au XX^{ème} siècle, dans toute l'Europe aura lieu un très fort mouvement de codification. Le Code général prussien de 1794 ou le Code civil napoléonien de 1804 par exemple.

Le modèle RG a été développé dans les universités mais aussi par la colonisation. Si l'on retrouve le Code napoléonien partout en Europe c'est parce que Napoléon l'a imposé en conquérant l'Europe.

L'avantage de ce type de droit est la clarté et la praticité. Le désavantage est la rigidité. Si tout est écrit et formalisé, il faut modifier le texte. Si l'on veut changer le texte, il faut un Parlement favorable.

Pour résumer, le modèle RG vient du SERG. C'est d'abord une redécouverte du droit romain au MA dans les universités. La codification est le critère principal de la famille du droit RG. On considère l'Europe occidentale comme étant l'origine du droit RG même si le droit codifié s'étend partout dans le monde.

1-2) Le modèle de Common Law.

Le droit de Common Law (CL) a été élaboré par les cours royales d'Angleterre. C'est le cœur du droit anglais. Historiquement, la formation de la Common Law est liée à l'unification de l'Angleterre autour de la monarchie. L'idée de la CL est qu'elle est un ensemble de règles qui vont se forger progressivement au cours de l'Histoire. Si l'on devait traduire Common Law en français, on dirait « droit commun ». Cette traduction est inexacte car le CL touche tous les aspects du droit. L'élément central et fondamental de la CL est qu'il se fait en grande majorité à travers la jurisprudence. La règle de droit résulte de l'interprétation du juge. C'est l'opposé du modèle RG. Dans le modèle RG classique, la jurisprudence n'est pas une source de droit. Dans le modèle de CL, le juge est créateur de droit. Il y a un principe fondamental appelé la règle du précédent (*stare decisis* en latin). Cette règle dit que les juges doivent suivre les décisions qui ont déjà été prises auparavant. Dans un système qui est basé sur la jurisprudence et l'interprétation des juges, cette règle permet la stabilité et la sécurité juridique. Les juges vont suivre la jurisprudence, ce qui permet de savoir à quoi s'attendre. Pour autant, des évolutions sont possibles. Elles se font par rapport aux évolutions de la société. Des règles et des lois adoptées par le Parlement vont faire évoluer cette jurisprudence. Le but est de minimiser au maximum les revirements de jurisprudence car ils posent un problème vis-à-vis de la sécurité juridique.

Pour résumer, l'idée est que la jurisprudence s'impose aux juges et que ce sont en priorité les jurisprudences des cours supérieures qui s'imposent.

Certaines institutions comme la Chambre des Lords au RU acceptent de s'écarter parfois de la jurisprudence. Elles considèrent que si l'intérêt de la justice l'exige, il est possible de s'écarter de l'interprétation passée.

Le principe du système de CL est que le droit écrit existe mais il reste minoritaire. Le système ne fonctionne pas sur le droit écrit. Par exemple, il n'y a pas de constitution au RU. C'est un ensemble de textes et l'interprétation qui en est faite qui régit la forme et les compétences de l'Etat au RU. L'avantage de ce système est le côté évolutif. Il permet une adaptation facile et il y a beaucoup moins ce phénomène de rupture qui suit un changement de loi ou de constitution. Depuis la Glorieuse Révolution en 1648, où s'est installée la monarchie parlementaire, il n'y a pas eu de changement de régime. Tous les changements se sont faits petit à petit, tandis que dans un système RG, les changements sont brutaux et occasionnent souvent des changements de régime. L'inconvénient du système de CL est la lisibilité. Ce système reste très ancré et se retrouve dans tous les pays anglophones. Le Canada a un système de CL mais le Québec est à mi-chemin entre le système de CL et le système RG.

Le cas des EU est encore un cas à part. Ils ont eu la première constitution écrite. Leur système date de 1777. A l'intérieur des EU, chaque état a sa constitution. Ils ont donc un droit très écrit. Pour autant, les juges américains se fondent énormément sur la CL. Le principe du précédent n'est pas totalement respecté aux EU.

1-3) Les traditions juridiques religieuses.

-La tradition juridique musulmane.

Le droit étatique va intégrer les règles de la Charia. Les règles religieuses sont codifiées. Ces règles vont régir la sphère publique et la sphère privée. La seule différence notable avec les autres systèmes est que puisque les règles découlent de la volonté de Dieu, elles ne peuvent pas être changées et les gouvernants ne peuvent pas s'en affranchir. Dans ce système-là, le juge a un pouvoir très important. Pour faire des règles religieuses des règles juridiques contraignantes, il faut que

quelqu'un les interprète. A part certains cas (comme en Iran), les tribunaux religieux ont disparu. Selon les pays, l'importance de ce droit religieux à l'intérieur du système juridique va varier. Dans des systèmes comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, le droit religieux est très important à l'intérieur du système juridique. On y considère que l'Etat a pour vocation de faire appliquer les lois religieuses. Dans la constitution iranienne, il est dit que l'objectif de la constitution est de créer un climat favorable au développement des valeurs morales sur la base de la foi et de la vertu, à fonder une économie saine et équitable reposant sur les principes islamiques et à élaborer la politique étrangère sur la base des valeurs islamiques. C'est une manière de mêler les éléments très concrets des missions de l'Etat en leur donnant un objectif religieux. Il y a des états dans lesquelles cette emprise de la religion est moins forte. Au Maroc ou en Algérie par exemple, à part la reconnaissance de l'Islam comme religion d'Etat, il n'y a pas d'implication de la religion dans le système juridique. La Charia n'est pas un fondement juridique ou une source de droit dans ces pays. A part le droit de la famille qui reste très imprégné de ces valeurs-là, les constitutions sont calquées sur un modèle classique occidental. Le droit positif est détaché de l'aspect religieux.

Les règles de la Charia ne peuvent être modifiées du fait qu'elle s'apparentent au droit naturel.

-La tradition juridique hébraïque/ juive.

Si on lit la Torah, on trouve les règles pour régir les rapports entre le individu et les rapports au niveau de la sphère publique. Toutes ces règles sont transposables dans le domaine public. Dans la Torah il y a 613 commandements qui ont source de droit et qui comportent des obligations et des interdictions. A côté du droit écrit il y a beaucoup de droit oral « le Talmud »; Cela apparaît comme un complément du texte. Ex: la Torah interdit de travailler le jour du Chabat cependant elle ne définit pas le terme travailler. C'est la loi orale qui va venir apporter des précisions, ressemble à la Common law, texte évolutif. Israël est un pays qui est au carrefour de la tradition religieuse (fondement théologique du système), Common law (ancienne colonie britannique), processus Romano-germanique qui s'est ajouté pour la codification. Aujourd'hui la tradition hébraïque dans le système juridique devient de plus en plus faible. L'aspect religieux est devenu un héritage culturel de la tradition juridique mais n'est pas du droit au sens que l'on entend.

1-4) Les traditions juridiques asiatiques.

Peut-on définir un droit asiatique?

Aujourd'hui ce qui domine c'est le modèle Romano-germanique. Cependant il y a quelques spécificités traditionnelles qui demeurent:

1-4-1) Japon

Au Japon pendant des siècles c'est la tradition Confucéenne (Confucius) qui va influencer la création du droit. Ce qui est très éloigné du modèle occidental. XII^{ème} siècle régime féodal basé sur des coutumes, ces coutumes qui régissent les rapports entre les individus s'appellent les *GERIS*. Pendant longtemps le droit japonais est resté fermé au monde extérieur, évite les influences du monde extérieur. Ce régime féodal prend fin en 1868. Ce qui se traduit par la restauration du pouvoir impérial. *Aire MEIJI*. Adaptation rapide du système juridique. Cette modernisation se fait à marche forcée, ils vont codifier rapidement en prenant pour modèle l'Europe de l'Ouest. *Code pénal japonais de 1880, CC japonais en 1898 et la Code du commerce japonais en 1899*. C'est grâce au code du commerce de 1899 que le Japon s'ouvre commercialement à la mondialisation. Si on regarde le contenu de ces codes on retrouve une grande partie du code français et allemands. Dernière étape s'effectue après la seconde guerre mondiale. Ces derniers perdant la guerre ce qui fait que les américains font entrer en vigueur une constitution qui va rentrer en vigueur en 1947. Ils imposent le pacifisme constitutionnel ce qui signifie que le Japon ne peut avoir d'armée autre que pour son auto défense. Le Japon souhaitant avoir une importance au niveau international ce qui remet en question sa constitution.

1-4-2) Chine

Système fondée sur une tradition philosophique. Origine philosophique chinoise traditionnelle ou va s'ajouter l'idéologie socialiste (régime de Mao). A la fin de son régime la tradition occidentale va s'imposer.

La tradition chinoise impose le respect des rites ancestraux. Les coutumes traditionnelles régissent la morale. Ce qui est décalé avec nos systèmes occidentaux c'est que l'homme est un membre de la communauté. Il n'est pas sujet de droit en tant que tel. L'individu se fond dans le corps de la collectivité. Proviennent du Confucianisme et Taoïsme. On ne parle pas de valeur on parle de régime coutumier et philosophique. Dans les concepts il y a le « FA » renvoi à la sanctions/ les règles contraignantes. Le premier code retrouvé en Chine est un code pénal. Le concept qui est au-dessus du « FA » est le « LI » qui est traduit en français par « le rite », régit tous les aspects de la société.

Pour *Confucius* « Le LI s'est l'ensemble des règles qui servent à gouverner l'état, à appliquer les règlements administratifs et à faire régner l'ordre dans la société ». Début du XXI^{ème} siècle grosse codification du droit. *Code pénal 1905*, puis le *CC en 1907*. L'objectif étant de montrer au monde Occidentaux une ouverture notamment sur l'aspect commercial.

Il veut faire table rase du passé et enlever les traditions cependant il faudra attendre les années 1990 pour avoir de nouveau

une politique d'ouverture qui nécessite une totale réforme du système juridique.

Ce mouvement politique implique de nombreux prêts auprès des occidentaux pour réformer le droit. Le fait de changer si vite de système est les incohérences des normes. Les rapports entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central en sont particulièrement victime. Selon le Li aller aux tribunaux est synonyme d'échec social.

1-5) Les rapprochements des modèles entre eux.

Selon les juristes les systèmes de droit s'uniformisent notamment grâce à la mondialisation. Les facteurs qui causent cette uniformisation:

- colonisations/ conquêtes militaires. Une fois la guerre gagnée on impose le système juridique. Travaux du Pr Roland: en cas de conflit de droit quel est le droit qui prime? Celui du pays coloniser ou du pays colonisateur? Cette question c'est beaucoup pose en Amérique du Sud. Il y a plusieurs modèles possibles:

-coopérations, on cherche à allier les règles entre elles.

-incorporation, on incorpore des règles à la juridictions déjà en place.

-rejet totale du système juridique, on le remplace par le système juridique du pays coloniser par celui du pays colonisateur.

Ex: Canada les peuples autochtones veulent conjuguer leurs droits avec ceux du Canada

Dans un aspect post-colonial, des pays qui vont continuer à appliquer les lois qui étaient en vigueur lors de leur colonisation.

Ex: En Afrique beaucoup d'ancien pays colonisés par la France ont gardé une constitution semblable à la constitution française et ce malgré la fin de l'occupation. Après la chute de l'URSS, la Lituanie, Lettonie ont une constitution qui ressemble beaucoup aux constitutions Occidentales. Volonté politique de faire partie du bloc de l'Ouest et de s'éloigner de la Russie.

- La Soft law contrairement à la règle de droit classique il n'y a pas l'aspect contraignant. Le but est d'amener un certain comportement à se réaliser, mais sans la menace d'une sanction. Par ex: en Europe, la Commission de Venise pour la Démocratie pour le Droit (CVDD). Rattache aux conseils de l'Europe, est un organe consultatif constitué d'experts indépendants venant de tous les pays européens. La CVDD n'a pas de pouvoir de contrainte mais elle va produire des rapports et des évaluations sur les agissements des différents pays rattachés au conseil de l'Europe. Elle rend des rapports sur les élections dans l'Europe. Elle a un pouvoir d'influence, volonté d'uniformisation dans ce qu'elle considère comme les bonnes pratiques démocratiques.
- Dialogue des juges, idée selon laquelle les juges d'un état vont se référer aux juges d'un autre état pour trancher le litige qui leur est soumis. Sauf en France où les arrêts sont rédigés de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de référence aux autres institutions juridiques. Mais au Canada par exemple, les décisions de juridiction font parfois mention des décisions d'institutions juridiques étrangères. En Europe, c'est principalement la CEDH qui va exercer une influence. Si un pays voit qu'un pays voisin est condamné, il va aligner son interprétation sur celle de la CEDH. Dans certains cas, un juge national peut poser une question en interprétation à la cour de justice de l'union européenne. Dans ce dialogue les juges, une juridiction se réfère à une solution d'une autre juridiction. C'est un dialogue implicite. Si une juridiction pose une question à la cour de justice de l'UE, c'est un dialogue explicite.
- Le quatrième élément est l'harmonisation de l'organisation internationale du droit dans tous les états membres. Quand un état rentre dans l'UE il accepte le droit européen et ratifie tous les traités européens. Il se doit de les respecter.

2) La classification de la diversité du droit en France.

En France il faut comprendre la structure du droit français.

Distinction entre droit privé et droit public (caractéristique des droits romano-germanique) dans le droit romain antique on retrouvée déjà cette distinction entre droit privé et droit public. Sphère privée régit les relations entre les individus.

Sphère publique organisations de l'état/ administration. Idée que l'on retrouve dans le droit romain antique Res Publica, idée de gestion en commun et l'idée d'une participation active du citoyen à la vie de la cité. Cette idée de sphère privée au RU n'est pas aussi développée et protégée. Ex: Presse va jusqu'au harcèlement des célébrités au RU. En France Art 9 CC encadre le droit au respect de la vie privée. Ce qui n'est pas le cas au RU. Quand il y a une question de droit fondamentaux qui se pose? Le juge doit arbitrer entre liberté de la presse et respect de la vie privée.

Il existe des droits mixtes.

2-1) Droit privé

L'ensemble des règles juridiques qui sont destinées à régir les relations entre les individus. Il s'applique à tous nombreux domaines différents (droit de la famille, des contrats, des relations professionnelles, etc). Au sein du droit privé il y a

plusieurs branches dont la principe est le Code Civil.

2-1-1) Droit civil

L'ensemble des règles juridiques qui concernent les personnes dans leurs sphères privées. On parle de droit commun. Le droit commun s'applique sauf si on a mis en place des règles dérogatoires au droit commun (droit spécial).

La norme de référence est le code civil de 1804. Et avant ça c'était les coutumes (droit coutumiers) et une influence de l'église (droit canonique) régissait les droits de la famille entre autre.

Sous Louis XIV fait plusieurs ordonnances qui ont pour vocations de s'appliquer sur l'ensemble du royaume. L'idée est de mettre en place un droit commun. Ex: Ordonnance de 1667 qui fixe la procédure civile. En 1669 ordonnance sur les eaux et forêts qui est toujours d'actualité.

A la révolution le droit civil va se laïcise, on écarte le droit canonique (y compris dans le droit de la famille). Distinction entre mariage civil et mariage religieux.

NB apporte le CC, ce dernier à pour but d'unifier et d'ordonner le droit civil sur tout le territoire.

Années 1960-70 et en 1985 modification importantes du CC par ex: les lois de Robert B vont modifier le CC en instaurant l'égalité entre les époux. Une autre loi de Badinter fait évoluer la responsabilité en ce qui concerne les accidents de circulations.

CC:

1er livre les personnes (divorces, mariages, filiations...)

2eme livre biens et propriétés

3eme manière d'acquérir la propriété

4eme droit des sûreté (garanties de paiement, le remboursement des dettes.

5eme Mayotte

2-1-2) Droit commerciale

C'est une partie du droit des affaires. On peut le définir comme « le droit qui réunit l'ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants et aux sociétés commerciales ». Comprend les activités bancaires, les fonds de commerce... Pour régir cela il y a un code du commerce adopté en 1807 qui a changé de nos jours.

Dans le droit commercial il y a des sous catégories comme le droit de la concurrence, droit bancaire, droit de la distribution...

Le droit commerciale est un droit dérogatoire au droit commun CC. Pour autant il ne s'applique pas à l'ensemble des acteurs économiques. Ex: fermier est régi par le droit rural dans ses activités.

2-1-3) Droit rural

L'ensemble des règles de droit applicables à l'activité agricole. La Politique Agricole Commune (PAC —> UE) influence sur le droit rural en France. Le droit de l'environnement a un impact considérable sur le droit rural. Dans le droit rural on retrouve des règles qui concernent le marché agricole, comme les Labels.

2-1-4) Droit social

Tout ce qui concerne le droit du travail. Relations employeur employeur et syndicats. Historiquement ce droit est le fruit de toutes les luttes politiques des ouvriers pour obtenir de plus en plus de protection.

En 1910 loi sur les retraites des paysans et ouvriers.

En 1936 Loi sur la semaine de 40h et les congés payés.

En 1968 mise en place du smic.

En 2000 loi sur les 35h.

Il y a un code du travail qui date de 1910, le souci étant l'inflation législative (des qu'il y a un problème on fait une loi). Le code du travail est refait en 1973 puis en 2008. Ces révisions sont faites pour que le droit social soit accessible et intelligible pour les employés qui n'y connaissent pas grand chose au droit.

Le droit de la sécurité sociale est également une partie du droit social. Il concerne les accidents et les maladies. Le régime commun de la sécurité sociale a été créé en 1946. Le code de la sécurité sociale régit toutes les activités liées à la sécurité sociale.

2-2) Droit public

Comment fonctionne l'état? L'organisation de l'état ?

La différence du droit public est que ce dernier rassemble les grands principes qui régissent les fonctions d'Etat.

2-2-1) Droit constitutionnel

Le droit constitutionnel est la norme suprême de l'ordre juridique, l'idée derrière ça est de limiter l'exercice du pouvoir. La première constitution française est faite sous une monarchie constitutionnelle. Ce qui est fondateur c'est la séparation des pouvoirs. Montesquieu « pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ».

Il y a des débats actuels pour savoir si aujourd'hui la séparation des pouvoirs est toujours d'actualité.

La constitution prévoit les valeurs défendues dans le préambule, on retrouve dans ce texte l'organisation de l'état et des institutions. On retrouve également les droits fondamentaux des individus.

France il y a un bloc de Constitutionnalité: constitution, préambule de 1946, charte de l'environnement 2004, DDHC. Le CConstitution leur a donné une valeur constitutionnelle en 1971.

Le dernier élément retrouvé dans la constitution est le mode de désignation des gouvernements. Art 6 « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. ».

C'est la constitution qui prévoit le mode de production des normes. C'est dans la constitution que l'on trouve la procédure pour faire des lois. Art 45 Constitution « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ». Dans la hiérarchie des normes il y a des lois et des traités, la constitution prévoit la procédure pour effectuer des traités. L'organisation de l'état (unitaire ou fédéral) est retrouvée dans la constitution. En France depuis 2003 on est un état décentralisé. La Constitution prévoit les rapports entre le niveau national et les collectivités territoriales (communes, départements, régions) Et comment sont répartis les compétences à l'intérieur de l'État.

Pour résumer, la Constitution édicte le droit des institutions nationales, les modalités de production des normes et l'organisation de l'État.

2-2-2) Droit administratif

On définit le droit administratif comme l'ensemble des règles juridiques relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics et de l'administration de l'état et des collectivités territoriales. L'objectif du droit administratif est la recherche de l'intérêt général. La difficulté avec cette notion est que c'est une notion floue.

On retrouve la réglementation des liens réglementés entre les administrations. C'est surtout la réglementation des liens entre l'administration et les administrés. Lorsque l'on a un conflit entre l'administration et un administré ce conflit est porté devant les juridictions administratives.

Fin du XIXe siècle il y a le droit du droit administratif qui correspond à celui appliqué aujourd'hui. Avant on parlait d'état arbitraire, le roi a le monopole de la contrainte et il n'y a pas de juges pour appliquer un droit spécifique à l'administration. « si veut le roi si veut la loi ». Alors que dans un état de droit, l'administration est soumise au droit. Ce qui permet de protéger les administrés contre l'administration. L'administration dispose d'une prerogative de puissance publique, c'est-à-dire que les décisions qu'elle prend, ce sont des décisions unilatérales qui sont contraignantes pour ceux à qui elles sont destinées. Cependant l'administré peut faire un recours pour « excès de pouvoir », on attaque l'administration en plaçant le fait que l'administration a outrepassé ses pouvoirs. Cela a nécessité une autonomisation des juridictions administratives par la loi du 24 mai 1873 que le CE devient véritablement une juridiction.

CE (conseil d'état), sert de conseiller du gouv sur les questions juridiques, sert aussi à juger la légalité des lois. Arrêt fondateur du droit administratif est l'arrêt Blanco du 8 fév 1873 arrêt rendu par le tribunal des conflits. Ce dernier est compétent quand on ne sait pas si c'est l'administration ou le judiciaire qui est compétent. Ex: petite fille renversée par un wagon de manufacture publique, le père va alors se tourner vers les tribunaux judiciaires alors que le tribunal des conflits va dire que ça relève des tribunaux administratifs. Consacre la responsabilité de l'état, l'état est responsable des manufactures qu'elle exploite et doit répondre de ces actes en cas d'accident.

2-2-3) Les finances publiques

Les finances publiques concernent les activités financières de l'état, des collectivités territoriales et des organismes publics en général. On distingue les finances en spécialités: droit fiscal public (impôts), la comptabilité publique (contrôle de l'argent public, gestion des détournements), droit budgétaire (ce sont les règles qui encadrent chaque année des lois de finances et de la mise en œuvre du budget prévisionnel).

Le parlement vote les lois de finance. Le gouv propose le projet de loi de finance.

La cour des comptes, gestion de l'agent public < administrations.

Antiquité on retrouve les memes questions de finances publiques.

Empire romain avait un système d'impôt très performant.

La révolution est la césure sur la façon d'appliquer ce droit, car avant c'était le roi qui décidais de prélever un nouvel impôts. La révolution française a amené l'assemblée nationale à déclarer nul tous les impôts car ils ont été mis en place sans le consentement de la population. Le premier principe instaure est celui de consentement à l'impôt. Art 14 DDHC Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.. « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution public, de la consentir librement ... ». Le deuxième principe affirme et l'égalité de tous devant les impôts. Art 13 DDHC. « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ». Fin des privilèges, et on permet un impôt progressif selon le revenu.

Il y a deux grandes périodes des finances publiques:

- Les finances publiques classiques XIXe au début XXe siècle. C'est l'idéologie libérale qui prévaut. L'état doit intervenir le moins possible dans la vie économique, état gendarme (état doit se limiter aux pouvoirs régaliens (police, armée, justice)). Etat dépense le minimum pour faire fonctionner l'état. De plus on attend que le budget de l'état soit neutre, il ne doit pas influencer l'économie.
- La période moderne des finances publiques fin de la deuxième guerre mondiale. État interventionnistes/ état providence. L'état intervient dans l'économie et dans les questions sociales. Création sécurité sociale. Dans la logique moderne de l'état providence est totalement inversé. On admet que l'état intervient dans l'économie pour influencer le comportement des entreprises et des consommateurs. RSA, retraites.. Avant 1914 les dépenses publiques représentaient 10/15% du PIB, aujourd'hui c'est 50% du PIB. Aujourd'hui les finances publiques sont gérées par l'UE. Surveillance de plus en plus forte de l'UE sur les dettes publiques.

Après la révolution française, il y a un consentement à l'impôt et une proportionnalité de l'impôts.

2-3) Les droits mixtes.

Le droit mixte n'entre pas, ni dans la catégorie droit public ni dans la catégorie droit privée. Ex: droit pénal. Les anciens auteurs ont longtemps mis le droit pénal dans le droit public car c'est le droit de punir de l'état.

Les auteurs contemporains l'ont mis plutôt dans le droit privée car cela met en jeu les intérêts privés.

En réalité ce passage du droit public au droit privée c'est un clivage de la doctrine. Ceux qui forment les étudiants sont des pénalistes de droits privés. Historiquement le droit pénal est un des droit les plus ancien.

Le but étant d'éviter un système né de vengeances privé (loi du talion œil pour œil). L'état détermine les infractions et les sanctions qui vont avec. Pendant longtemps MA c'est l'arbitraire qui prévalait (le juge décide du châtiment) sans qu'il y ait forcément une infraction prévu au préalable. Ce sont les philosophes des lumières qui se sont insurgés sur ces pratiques, ils défendaient le droit de connaître la prévisibilité des sanctions. Ils demandaient aussi que la loi soit la même pour tous « légalité des peines ». Art 7 DDHC « nul homme ne peut-être accusé arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrite. Art 8 DDHC « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... Nul ne peut-être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué ».

Cesare Beccaria traite des délits et des peines 1764. Rationalise le droit pénal avec l'idée que la loi sur le fondement de laquelle le juge prend sa décision doit définir l'incrimination et la peine encourue. Ex: 221-1 CP « le fait de donner volontaire la mort à autrui constitue un meurtre, il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. ».

De manière générale le droit pénal est la branche qui définit les infractions.

Incrimination : le fait d'ériger un comportement interdit

Infraction: le fait d'enfreindre cette règle de droit

Les infractions sont classées en fonctions de leurs gravités. Contraventions (5 classes) < délits < crimes. Le droit pénal est imprégné de moral. Le but étant d'assurer la paix publique et surtout la sécurité des personnes et des biens.

Le droit pénal est codifié et date de 1790. Mais le principal est le code pénal de 1810, cependant le droit pénal est assez violent (marquage au fer rouge). Actuel 1994, cependant il y a eu beaucoup de modifications.

Chapitre 4 : Les sources du droit.

Comment le droit est créé. France tradition romano-germanique c'est un droit écrit. Les sources formelles du droit.

Il y a aussi les sources informelles du droit (jurisprudence, coutume, doctrine...)

1) Les sources formelles du droit

1-1) La constitution

Dans le droit romains les constitutions étaient les lois adoptées par l'empereur. Ces lois étaient unilatérales et arbitraires de plus elles relevaient du droit civil.

Le terme est issu de la philosophie des lumières et des révolutions françaises et américaines. En principe la constitution est un document unique qui contient toutes les règles qui régissent l'organisation de l'état et l'exercice du pouvoir. La France est une exception car sa constitution ne contient pas qu'un seul document.

On peut faire une différence entre les constitutions écrites et constitutions coutumières

1-1-1) Constitution écrite ou constitution coutumière

La plupart des constitutions sont écrites. Pour plusieurs raisons:

- Lisibilité
- Sécurité juridique (les gouvernements vont être contraint par ces règles)
- Stabilité du système (la constitution est une norme difficile à modifier)

La première constitution écrite est la constitution américaine, elle n'a jamais changé cependant il y a eu des modifications. Les États Unis en sont à leur première constitution alors qu'en France nous en sommes à la 15^{ème} constitution.

L'autre forme étant la constitution coutumière exemple RU. Et cela correspond au modèle du Common-Law. Ils ont pourtant des textes « magna carta » de 1215 ou le « bill of right » 1689. Puis en 1919 « acte sur le parlement » modifié en 1949 (limitation de la chambre des lords au profit de la chambre des communes). Au RU il y a une souveraineté parlementaire. Cela signifie que les lois adoptées par le parlement n'ont pas de normes supérieures. Cependant les conventions constitutionnelles sont dans la pratique politique. Ce sont des pratiques politiques qui sont respectées par les différents acteurs politiques et qui deviennent des règles. Ex: le premier ministre doit démissionner s'il perd la confiance de la majorité à la chambre des communes.

1-1-2) La norme suprême adoptée par le souverain

Ce qui justifie que les constitutions sont les normes suprêmes c'est le fait que ces dernières découlent de la volonté du peuple.

La base du concept de souveraineté est un pouvoir absolu et illimité. J. Bodin dans les six livres de la république.

Aujourd'hui on dit que le peuple est souverain (l'ensemble des individus physiques) qui vivent sur un territoire: ce qui donne la « théorie de la souveraineté populaire » de J.J. Rousseau dans *Le contrat social* 1762. Art 25 constitution 1793 « le peuple souverain est l'universalité des citoyens français ». Chacun détient une part de la souveraineté, cependant cette constitution n'a jamais été appliquée pas plus que la théorie de Rousseau. Car la souveraineté populaire impliquerait une démocratie directe. Il y aurait des référendums sur tous les sujets.

L'autre théorie est celle de la souveraineté nationale. Idée que la nation n'est pas l'ensemble des citoyens, on est dans quelque chose d'abstrait qui réunit les citoyens à l'instant T et des citoyens qui ont existé avant. La nation, il faut qu'il y ait une histoire commune.

Justifie qu'il y ait des représentants pour exprimer la volonté de la nation.

L'auteur de référence est Sieyès « qu'est-ce que le tiers état » 1789

Art 3 DDHC « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». C'est la seule représentation viable. Aujourd'hui dans la constitution de 1958 on trouve l'ensemble des deux théories dans l'article 3 ...

Ces deux théories étant de la doctrine on peut effectuer un non choix entre ces deux théories.

Le souverain s'exprime par des référendums, référendums constitutifs, projet élaboré par une assemblée constituante, à la fin ce projet est voté au référendum. Dans l'actualité il y avait un référendum au Chili qui a été refusé. Pour éviter que le peuple refuse le projet il peut arriver que ce soit l'assemblée constituante qui fait le projet et qui l'adopte à la fin. Cette option a été choisie pour les printemps arabes.

Ce qui fait que c'est la norme suprême c'est qu'elle ne peut pas être modifiée par une autre norme. Une loi ordinaire ne peut pas changer la constitution. Un traité ne modifie pas la constitution. Le seul moyen de la modifier est la révision constitutionnelle, elle est hors d'atteinte des autres normes.

Constitutions rigides: pour modifier la constitution il y a plus de contraintes que pour changer les lois ordinaires. Assure la stabilité du régime.

Constitutions souples: elle est souple quand elle peut être modifiée dans les mêmes conditions qu'une loi ordinaire.

Dans la plupart du temps on fait appel à une constitution rigide. Pour la France c'est Art 89 de la constitution. Il y a plusieurs étapes à franchir avant une révision. Déjà on dépose un projet (gouvernement) ou une proposition (parlementaires). Les deux assemblées vont alors débattre. Pour les lois ordinaires le dernier mot revient à l'assemblée nationale. Pour les révisions il n'y a pas de dernier mot. Le Sénat a un pouvoir de blocage constitutionnel. Puis la dernière étape est le référendum ou on réunit les deux assemblées en congrès, et il faut avoir une majorité des 3/5 des votes. Au-delà de la France il y a des pays où la révision de la constitution est presque impossible. Ex: Canada qui est un état fédéral divisé en plusieurs provinces, pour réviser la constitution il faut mettre d'accord toutes les provinces. Ils font des accords à la constitution.

1-1-3) Les fonctions de la constitution

- Déterminer l'organisation des pouvoirs, définir quelles sont les institutions et quelles sont leurs compétences.
- Fonder la validité de l'ordre juridique. Car c'est elle qui détermine comment produire les autres normes.
- Elle détermine le mode de désignation des gouvernements. En pratique elle prévoit les modes d'élections, les durées de mandats. Cela permet de donner une légitimité aux gouvernants pour prendre des décisions au nom du peuple.
- Garantir des droits et libertés aux individus qui vont s'imposer aux gouvernants. Cette contrainte s'applique par le biais du Conseil Constitutionnel. (Les droits fondamentaux: droits au plus haut niveau international, droit public: droit et liberté consacrés dans les lois.)

1-2) Le droit international

La question qui se pose, les traités sont-ils au-dessus ou en-dessous de la constitution?

Art 55 de la constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur application une autorité supérieure vis-à-vis des lois.

Art 54 Constitution le CC peut faire un contrôle entre un traité qui n'a pas été ratifié et la constitution telle qu'elle est au moment du contrôle. En cas d'incompatibilité c'est la constitution qui faut modifier. Soit on considère que le traité est supérieur et on change la constitution. Soit on décide que c'est la constitution qui est supérieure au traité, elle va donc déterminer le mode de ratification du traité.

Def droit international: c'est la droit qui regroupe les règles juridiques qui régissent les rapports entre les sujets du droit international (Etats). Pour autant, de plus en plus il y a des organisations internationales, ce sont des organisations créées par des Etats. ONU, OMC...

Ne pas confondre avec les ONG. La mondialisation économique a une très grande influence sur le domaine économique.

1-2-1) Le droit international inter-étatique

Traité internationaux sont des accords passés entre des Etats souverains. Et les Etats s'engagent à les respecter. Les traités remontent aux traités de 1648 de Westphalie. Naissance du droit international moderne. Idée posée: les Etats sont égaux, ils passent des accords entre Etats souverains. Ces accords sont des contrats passés entre Etats. Traités = conventions = accords = protocoles = pactes. Cela se résume à des accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans la terminologie il faut faire la distinction entre disposition (les lois) et stipulation (réserver aux contrats, dont les traités).

Possibilité de mettre fin aux engagements. Dénoncer un traité. Ex: Brexit. Cela ne peut pas être un retrait unilatéral selon la convention de Vienne de 1969 qui est un texte important car il ratifie le droit qui régit les traités internationaux. Art 56 de la convention de Vienne, interdiction de se retirer unilatéralement sauf si tous le monde l'avaient prévu dans le traité.

Cette idée de relations de droits inter-étatique est très ancienne. Ex: premier traité retrouvé 2 500 ans A-J.C. C'est la mode privilégiée de nos jours pour faire des accords. Pendant très longtemps le droit international était coutumier.

On a gardé la solution écrite pour la stabilité du contrat.

Pour que le traité entre en vigueur il y a plusieurs étapes:

- Les négociations (pendant cette étape les Etats peuvent émettre des réserves, volonté de modifier certaines parties ou exclure certaines parties du traité) cette pratique est acceptée par la convention de Vienne Art 2§1.
- La signature du traité pour acter la forme finale du texte.
- La ratification du traité par les Etats. Le fait que l'Etat exprime son consentement à être lié par le traité. Cela se concrétise en droit interne par une loi de ratification. La loi en France oblige la ratification des traités de paix et de commerce Art 53 constitution. Le président de la rep est compétent pour signer et ratifier les traités. Il peut y avoir un référendum pour ratifier un traité. Ex: traité de Maastricht (1992) qui pose les bases de l'UE.

Ce recours au référendum est devenu obligatoire pour l'adhésion d'un nouveau membre de l'UE Art 88-5. Nécessite d'une consultation des pops concernés pour les traités de cessions, échanges ou adjonction d'un territoire. Pour autant le respect des traités repose sur la volonté des Etats à se plier à leurs engagements. Il existe des juridictions internationales (CEDH)

elles ne peuvent pas obliger un état à modifier son droit interne. Les condamnations de la cour européenne sont pécuniaires. Les Etats sont souverains donc ils s'auto-limitent en signant des traités. Cette règle d'auto-limitation est la règle « *pacta sunt servanda* » les conventions doivent être respectées de bonne foi par les états.

Ex: France alinéa 14 du préambule de la constitution de 1946 « la république française fidèle à ses traditions se conforme aux règles du droit internationales public ».

France il y a le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité (juges vérifient que les lois respectent les conventions).

1-2-2) la convention européenne des droits de l'homme

Ce traité est créé fin seconde GM. Le traité est signé par les membres du conseil de l'Europe en 1950 et il est rentré en vigueur en 1953.

Conseil de l'Europe : 46

Union européenne : 27

Pour que les droits soient respectés par les états, création de la CEDH en 1959, ce ne sont pas les états qui saisissent la CEDH, ce sont les ressortissants des 46 états membres qui peuvent une fois qu'ils ont épuisé les voies internes du pays saisir la CEDH.

Il y a un filtrage dans les affaires soumises à la CEDH.

Les condamnations de la CEDH ne sont pas contraignantes elles sont pécuniaires. Cependant elle a un grand pouvoir d'influence ce qui oblige les pays à suivre les dispositions.

Le problème que l'on va avoir prochainement avec la Hongrie, Pologne et l'Italie va être de savoir si les conventions vont être respectées.

UE est une organisation internationale qui réunit 27 états. C'est une organisation internationale inédite, car les états membres ont acceptés de délégués énormément de compétence à une organisation internationale.

Ce qui a fondé l'UE sont les traités, que l'on nomme le droit primaire. Le premier traité est celui de la CECA (communauté euro du charbon et de l'acier) les 6 états fondateurs sont: France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Italie. Uniquement dans une logique économique de commerce. Deuxième étape est la création de la communauté économique européenne, fait avec l'adoption du traité de Rome 1957. On reste avec les 6 états fondateurs mais on élargit à d'autres domaines, le but étant la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Puis vient l'acte unique Euro 1986.

L'acte fondateur de l'UE est le traité de Maastricht, création de la citoyenneté européenne. Libre circulation des personnes ayant la citoyenneté européenne. Volonté de création d'une monnaie unique et de la banque centrale européenne. On délègue des fonctions de compétences, pour exercer ces compétences en commun. Ex: PAC, l'environnement, la culture.

Traité d'Amsterdam en 1997.

Traité de Nice en 2001.

Tentative du TECE en 2005.

Traité de Lisbonne de 2009. Le traité de Lisbonne est le traité du TECE qui est passé par le congrès. C'est un scandale politique.

Le risque de ces traités est de perdre la cohérence des systèmes.

Le traité de Lisbonne a permis de clarifier le fonctionnement de l'UE. Ce dernier se décompose en 2 traités. TUE (traité sur l'UE, porte sur l'organisation des institutions). Le deuxième traité est le TFUE (traité sur le fonctionnement de l'UE, ce traité prévoit le fonctionnement des institutions).

Les pays membres sont-ils toujours souverain alors qu'ils délèguent de plus en plus de pouvoir.

Argument des souverainistes: exemple du Brexit.

Un autre élément important dans le traité de Lisbonne est la création d'une charte de droits fondamentaux. Problème du doublon avec la CEDH.

Il y a aussi le droit dérivé, c'est l'ensemble des normes qui sont adoptées par l'ensemble des institutions européennes. Il y a les directives et les règlements.

Règlement: d'application directe dans les états membres. Cela signifie que c'est des normes contraignantes. Le but de ces institutions est l'uniformisation du droit dans l'UE.

Directives européennes : moins directement contraignantes. Pour que ces directives deviennent contraignantes dans les états membres il faut une transposition en droit interne. Elle n'est pas d'application immédiate. Les parlements nationaux doivent adopter une loi de transposition.

1-3) la loi

La loi est en-dessous des traités Art 55 de la constitution et Art 61-1 Constitution. France il y a le légicentrisme, les

procédures d'élaborations des lois: procédures ordinaires, procédures dérogatoires et enfin on verra les différents types de loi.

1-3-1) La tradition française du France le légicentrisme

Auteur de la doctrine qui ont créés cette théorie, le but étant d'en faire la norme la plus importante. La révolution crée une rupture, cela amène au légicentrisme jusqu'à la IVe rep. Le légicentrisme va à l'encontre de la théorie de la hiérarchie des normes. On est dans une logique du centre plutôt que dans une logique de hiérarchie. Le contrôle de constitutionnalité des lois date de 1958. Avant 1958, les lois ne pouvant pas être contrôlés on ne peut pas dire que la loi respecte la constitution, c'est le parlement qui effectuait lui-même le contrôle. Souveraineté parlementaire ou de parlementarisme absolu. Cela veut dire que le parlement n'avait aucune contrainte juridique extérieure. Art 6 DDHC « la loi est l'expression de la volonté générale ».

Le but étant de justifier l'intérêt des lois vis-à-vis de la nation. Le parlement représente la nation.

Logique de hiérarchie des organes, vu que c'est le parlement qui adopte des lois que ces lois ont une valeur supérieure. On est une toute puissance du parlement. Cette tradition s'est érodée. Sous la IIIe et IVe rep cette théorie est toujours supérieure, cependant il y a de plus en plus de personnes qui vont critiquer cette souveraineté parlementaire. Mise en place d'une instabilité gouvernementale. Prédominance du parlement sur le gouv.

La Ve rep a voulu rompre avec le parlementarisme. On est passé d'un parlementarisme absolu à un parlementarisme rationaliser. Le parlement n'est plus souverain. Création du CC pour la vérification de la constitutionnalité des lois. La doctrine à considérer qu'on est passé d'un état légal à un état de droit. Dans l'état légal ce qui prime c'est la loi. Alors que ce qui prime dans l'état de droit c'est la constitution qui prime. On reprend une hiérarchie des normes. Art 34 de la constitution, domaine de la loi, domaine dans lequel le parlement peut faire des lois. Le parlement peut légiférer sur un domaine cloisonné. Création de l'Art 37 pouvoir réglementaire.

1-3-2) Fabrication ordinaire d'une loi

C'est un processus long (plusieurs mois), raison pour laquelle quand un candidat est élu il lance toutes ses réformes au début.

Une loi: une norme à valeur législative votée par le parlement selon la procédure établie par l'Art 45 de la constitution et dans les domaines prévus par l'Art 34.

• Initiative

Soit c'est un projet de loi qui vient du gouvernement, soit c'est une proposition de loi qui vient des parlementaires. Les projets de lois commencent en amont dans les ministères.

• Puis il y a un avis obligatoire du CE.

Puis (Ex: environnement (il faut un avis du conseil économique et environnemental)) (enfin il arrive devant le parlement).

Initiative législative partagée, cela signifie que le gouvernement et les parlementaires ont le droit d'initiatives des lois.

• Commission

La proposition de loi passe ensuite en commission parlementaires, qui vont être dans des commissions spéciales (commission des finances, commission des affaires étrangères, commission des affaires économiques, commission des affaires sociales), les parlementaires peuvent faire des auditions pendant les commissions. La commission rend un rapport et peut faire des amendements (proposition de changement dans le texte) au texte initial.

Le parlement vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Aux moments des questions au gouvernement, c'est le moment où l'opposition questionne le gouvernement.

• Séance publique

séance publique dans l'assemblée nationale ou le sénat. Opposition, majorité et autres vont proposer des modifications du texte. Art 44 de la constitution. Droit partagé entre le gouvernement et les parlementaires. La majorité vote le texte dans tel ou tel version.

• Navette parlementaire, c'est la navette parlementaire, la majorité du texte voté va aller au sénat. Art 45 de la constitution. Après deux lectures il va y avoir la 5ème étape

• Réunion mixte d'une commission parlementaire (réunion en part égale de sénateur et de députés).

Le but étant de trouver un compromis pour la loi. Si aucune entente n'est trouvée c'est à l'assemblée nationale que revient de trancher.

1-3-3) Fabrication dérogatoire d'une loi

Ce sont les procédures qui ne rentrent pas dans le cadre de la procédure ordinaire. Le but étant d'accélérer les délais.

- Ordonnances, Art 38 de la constitution. « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Le gouvernement demande l'accord du parlement qui passe par une loi d'abolition. Le but étant dans une durée limitée et dans un domaine déterminé que le gouv puisse prendre des ordonnances qui ont valeur de lois.

Le cadre étant posé par la loi d'habilitation du parlement la fin de la procédure est faite par une loi de ratification (le parlement accepte que ces ordonnances deviennent des lois permanentes). Dernière étape étant la vérification du CConst. Cette procédure a été faite dans la constitution pour intervenir dans l'urgence (attentats, épidémies ...).

Cela devient de plus en plus la norme, il y a un empiètement de l'exécutif sur le législatif.

- Procédure de l'Art 49 alinéa 3. C'est une arme donnée à l'exécutif. Le but de la IVe rep était de donner des armes à l'exécutif pour se défendre du législatif. Cette procédure est un passage en force. Quand le gouvernement la déclenche il met fin aux débats de l'assemblée nationale, on va considérer que le projet de loi est adopté. Le seul moyen pour les parlementaires d'annuler cette loi est de faire une motion de censure pour renverser le gouv. En 2009 on a limité les conditions d'utilisation de l'art 49 alinéa 3.

1-3-4) Différents types de lois

Il y a différentes normes que l'on appelle des lois.

- Ce sont les lois organiques. Elles précisent la constitution. Ex: révision Art 61-1 avec la QPC par le renvoi à une loi organique. Cette loi pose qu'il faut une mesure de filtrage (conditions), elle apporte les détails de l'éligibilité de la QPC. Elle va être adoptée selon l'Art 46 de la constitution, elle fait l'objet d'un contrôle systématique par le CCont. ...
Président de la rep, président du sénat, président de l'assemblée nationale ou 60 députés ou sénateurs qui peuvent saisir le CConst.

- Lois référendaires: lois adoptées directement par le peuple. Dans la constitution il y a plusieurs Arts sur le référendum. Les référendums sont les procédures qui donnent au peuple la possibilité de prendre des décisions. Ils peuvent être organisés au niv national ou au niv local. Art 72-1. Le plus connu étant la procédure de l'Art 11 de la constitution dans laquelle l'initiative du référendum revient au président. Il va pouvoir soumettre un projet de loi au peuple. Le fait que se soit le président qui est la main mise sur la possibilité de faire un référendum est la création d'un référendum d'initiative citoyenne. Les domaines où le président peut faire un référendum: l'organisation de pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale de la nation. Ou sur la ratification d'un traité.

Les lois référendaires ont une spécificité, elles ne peuvent pas être contrôlées. Le CConst a refusé dans sa jurisprudence du 6 nov 1962 de vérifier les lois référendaires car « c'est l'expression directe de la souveraineté nationale » par conséquent il n'est pas compétent pour la contrôler.

Le référendum de 1962 était très critiqué du fait que le GDG a utilisé un moyen détourné pour réviser la constitution.

La procédure instaurée en 2008 se nomme la procédure référendaire d'initiative partagée. L'initiative vient 1/5 des parlementaires soutenu par 1/10 de oui du corps électoral français. Les assemblées peuvent se saisir pour éviter le référendum.

- Les lois de finances. La loi de finance va fixer un budget prévisionnel pour le fonctionnement de l'état. Il y a d'une part les dépenses envisagées, crédits accordés aux différents ministères.... Et les différents impôts envisagés. Loi de finances rectificatives peuvent être faites en cours d'année. Procédure d'adoption de la loi de finance est prévue à l'Art 47 de la Constitution. C'est une procédure simplifiée. Pour être plus rapide sur l'adoption de ces lois, car il faut que la loi soit votée avant le 31 décembre. Pour accélérer on impose des délais strictes. Art 47 renvoi à une loi organique. Cette dernière étant la loi du 1 août 2001 « Loi relative aux lois des finances ». Cette loi va intégrer des nouveaux principes. On rentre dans une logique de gestion financière, logique de performance, d'efficacité et de résultats.

1-4) Le pouvoir réglementaire

Normes adoptées par le pouvoir exécutif et les autorités administratives. Cela permet de prendre des décisions unilatérales qui ont une force contraignante et qui s'imposent à leurs destinataires. On parle alors d'actes exécutoires Art 37. Il reste cependant le risque que le parlement sorte de son domaine d'attribution. Le CConst a pour rôle de surveiller les domaines législatifs des pouvoirs exécutifs. Au niveau national le pouvoir réglementaire appartient au PM en vertu de l'Art 21 et également au président de la rep en vertu de l'Art 13.

Pouvoir réglementaire au niveau des collectivités locales Art 72 qui est inférieur au pouvoir réglementaire national. Ex: le

maire refuse un permis de construire.

Le pouvoir exécutif est la pour exécuter les lois. Grâce à des décrets d'applications. Le problème est quand le gouvernement prend du temps à faire un décret d'application. En principe en vertu de l'Art 21 le PM est dans l'obligation de prendre des décrets d'applications dans un délais raisonnable.

Arrêt du 24 nov 1963 obligation qu'a le gouv a prendre des décrets d'application dans des délais raisonnables.

Le pouvoir réglementaire autonome qui relève de l'Art 37. L'exécutif peut prendre des décisions en dehors des décrets d'applications. C'est le cas des ordonnances. Au niveau préfectoral on parle d'arrêtés préfectoraux car il a un pouvoir réglementaire au niveau local.

Contrôle de légalité, c'est le contrôle des actes administratifs par rapport à la loi.

2) Les sources informelles du droit

2-1) Coutume

Coutume est une règle non écrite qui s'est faite au court du temps. Différence avec la loi. La loi vient d'en haut (élaborer par les représentants élus) la coutume vient d'en bas (pratiques populaires). Cette création échappa au gouvernants. C'est le fait qui prédomine sur le droit, c'est une création factuelle. L'avantage de la coutume c'est le caractère souple et évolutif, la coutume est plus adaptée au faits. Elle s'adapte mieux à la réalité sociale. Alors que la loi c'est la projection objective du droit vu par les politiques.

En France nous sommes dans un modèle Romano-germanique, donc la coutume est de plus en plus faible voir inexistante.

2-1-1) Place de la coutume du MA à la modernité

La place de la coutume du MA à la modernité

C'est à partir du XI^e siècle que la coutume apparaît sur le territoire du royaume français. Il faut savoir qu'à cette époque c'est la coutume qui est la source principale du droit. À l'origine la coutume est liée aux prélèvements des impôts par les seigneurs. À l'époque c'est ce que l'on appelait le droit de BAN (ensembles des taxes et redevances que le roi pouvait prélever). Cette idée des coutumes permanentes d'imposer des limites aux seigneurs pour éviter qu'ils abusent de leurs pouvoirs. Ex: si un seigneur voulait faire une nouvelle taxe qui n'était pas une coutume, s'il n'arrivait pas à rattacher cette nouvelle taxe à une coutume ancienne, cette nouvelle taxe pouvait être dénoncée par les sujets.

Au XII^e siècle on évolue vers une protection plus importante des sujets envers les seigneurs à travers les « franchises » (c'est les libertés accordées aux sujets qui vont limiter ce que le seigneur peut exiger de ses sujets). Les coutumes vont aussi régir les rapports entre les individus. Et ses coutumes font être présent dans tous les aspects de la vie sociale. Pratique qui doit être continue et répétée.

Les modes de successions, la propriété foncière sont des droits coutumiers, l'exception qui échappe à la coutume c'est le mariage (droit canonique).

- Le principal problème est l'uniformité de la coutume. Les coutumes ne sont pas les mêmes au Nord et au Sud. Il y a un morcellement juridique du territoire.
- Le deuxième problème est que les coutumes ne sont pas écrites il y a donc un problème de connaissance et de diffusion des coutumes. Le problème que cela va poser c'est le problème de la sécurité juridique.

Voltaire dans son dictionnaire de philosophie de 1764 dira que « il y a 144 coutumes en France qui ont force de lois, ces lois sont presque toutes différentes, un homme qui voyage dans ce pays change de loi presque autant de fois qu'il change de cheval de poste ».

- Le troisième problème étant la formation de la coutume. Combien de temps faut-il pour valider la création de la coutume.

Dès le milieu du XII^e siècle on a voulu codifier ces coutumes. Au sud ce sont les seigneurs qui contrôlent les coutumes et ils prennent la forme de statuts urbains. Au nord ça va prendre la forme de recueil de coutumes (compilations des coutumes, et de commentaires). Ces recueils de coutumes sont rédigés par des particuliers. Le problème étant que ces recueils n'ont pas de valeur juridique contraignante. Ex: XII^e siècle les « Coutumiers de Normandie ».

Comment s'en prévaloir devant un juge?

- Coutumes notoires, elles s'imposent et n'ont plus de discussion sur la question. Elles peuvent être invoquées dans un

procès.

— Si ce n'est pas une coutume notoire celui qui s'en prévaut doit prouver son existence.

XVe siècle le système d'uniformisation va se faire sous la monarchie. Le roi est le gardien des coutumes. Il est là pour faire respecter la coutume. Il devient par la suite le gardien des Bonnes Coutumes (il distingue bonne et mauvaise coutume). Il ne peut pas créer la coutume mais il peut définir la bonne et la mauvaise coutume.

Le règne de Charles VII (roi qui gagne la guerre de 100 ans), grâce à cette légitimité il va mettre les coutumes officielles par écrit, ces dernières vont s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Le but étant d'instaurer une sécurité juridique.

Ordonnance de Montils-les Tours de 1453. « Interdiction aux avocats de proposer d'autres coutumes que celles qui ont été codifiées ».

Il faudra attendre le XVIe siècle pour avoir une réelle codification des coutumes par écrit et qu'elles soient respectées. Ces coutumes vont demeurer jusqu'à la révolution. Le problème étant le gommage des traditions locales. Les codes napoléons sont les réels codifications.

Art 7 du CC de 1807 « À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code ».

Ce processus s'est développé au fil des années.

Pour résumer : MA forte tradition coutumière, qui posait des difficultés car les coutumes étaient différentes dans l'ensemble du territoire. De plus on ne savait pas à partir de quand une coutume était considérée comme adoptée. Cela même à un problème de sécurité juridique.

Code napoléonien qui viennent fixer les coutumes.

2-1-2) Définition juridique de la coutume

La coutume est un droit non écrit qui naît de la pratique d'un groupe d'individu. Pour qu'elle soit reconnue il faut que les actes soient répétés sur un temps suffisamment long pour que cette pratique devienne une règle de droit qui devienne obligatoire.

Aujourd'hui il faut 2 éléments :

- Élément objectif, répétition d'une pratique précise pendant une durée suffisamment longue par une communauté humaine déterminée. On demande une continuité dans la pratique de la coutume.
- Élément subjectif, plutôt d'ordre psychologique car elle résulte de la croyance du caractère obligatoire de la pratique répétée. C'est la conviction collective et personnelle que la coutume est obligatoire et doit être respectée.

Cela permet de distinguer la coutume de l'usage.

Ex : nom de famille que l'on donne aux enfants. La règle de droit a été posée par la loi du 4 mars 2002 que l'on va légiférer et fixer une loi sur cette question. Jusqu'à ce moment là il n'y avait qu'une coutume datant du MA qui voulait que les enfants légitimes reçoivent le Nom du père. Cette coutume a vécu jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui c'est l'Art 311-21 CC « ... soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. ... ».

2-1-3) Portée de la coutume

Dans quelles mesures la coutume peut s'appliquer en droit ?

Aujourd'hui la coutume est une source du droit résiduel face à la loi. Pour autant la coutume pourra s'appliquer dans trois hypothèses :

- Si la loi y fait référence. *Secundum legem* d'après la loi. Art 521-1 CP « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ... Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
- Si la coutume vient compléter la loi. *Praeter legem*.
- Si une coutume irait à l'encontre de la loi. *Contra legem*. La loi est tombée en désuétude, on va donc appliquer la coutume. Ex : ordonnance du 7 nov 1800 prise par le préfet de Paris. Cette ordonnance prévoyait que les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon sauf sous certificat médical. En 2003 c'est un message du ministre du droit des femmes qui a dit qu'il y avait une abrogation implicite de cette ordonnance. En disant que c'est contraire aux principes d'égalité des hommes et des femmes sur le fondement de la DDHC.

2-2) Jurisprudence

Historiquement en France il y avait une méfiance à l'égard de la jurisprudence pour considérer que c'était une source du droit. Ces méfiances sont dus aux parlements de l'ancien régime. C'était des juges qui avaient abusés de leurs pouvoirs pour créer du droit à travers leurs jurisprudences. Adage *méfions nous de l'équité des parlements*. Rupture à la révolution, on a voulu subordonner les juges à la volonté du législateur. Citation de Montesquieu « le juge est la bouche de la loi ». Son rôle se limite à mettre en œuvre la loi qui est générale à des cas particuliers. Théorie légicentrisme (loi qui prédomine). Volonté de limiter l'interprétation du juge.

Référés législatifs, juge qui demandait au parlement comment il fallait appliquer le texte qu'il avait produit. Ces derniers ont été supprimés en 1837.

On trouve encore des traces de cette méfiance à la gère du juge car on ne parle pas de pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire.

Même si la jurisprudence n'est pas une source formelle du droit, elle a cependant acquis au cours de ces dernières décennies une place considérable au travers des droits fondamentaux.

2-2-1) Définir la jurisprudence

Étymologiquement la jurisprudence c'est la science du droit et l'opinion de ceux qui connaissent le droit. La jurisprudence est Def « comme l'ensemble des décisions de justice rendue pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du droit, soit dans l'ensemble du droit ».

- Définir la jurisprudence comme le répertoire des solutions jurisprudentielle, et œuvres des tribunaux. Cette définition est vu à travers l'application de droit par les tribunaux.

Ex: Année 2021 domaine civil et commerciale 1 380 000 décisions rendues.

Ex: Année 2021 domaine pénal c'est 1 830 000 décisions rendues.

- Aborder la jurisprudence comme une interprétation du droit. Ce n'est pas seulement un ensemble des décisions de justice mais c'est l'interprétation donner à une règle de droit.

L'interprétation authentique: interprétation contraignante. Ex: juge qui rend une décision contraignante.

L'interprétation doctrinal: il n'y a pas d'effet juridique contraignants. Ex: Commentateurs commentent un texte de loi.

2-2-2) La jurisprudence est une source du droit

Les décisions du juge ont une autorité de chose jugée (idée d'obligation), mais c'est pour autant c'est une autorité relative de chose jugée au niveau de la justice. La décision ne vaut que pour le litige. Pas de portée générale. On cherche à uniformiser la JP. Dans quelle mesure ces décisions peuvent devenir des normes générales qui s'appliquent au-delà du cas particulier. Le but étant d'avoir une interprétions uniforme du droit.

Ce qui fait d'une jurisprudence classique d'une jurisprudence constante. Elle se forme de différentes façons:

- Répétitions dans le temps de la même interprétation d'un texte (comme la coutume).

En France on est dans un système hiérarchisé (trois niv de Cour). Arrêt de principes, c'est la que les juridictions suprêmes vont faire des formulations générales des textes.

Formulation de la décision. On regarde la formation qui rend la décision au sein de la juridiction. Ex: au sein de la Cour de cassation il y a plusieurs chambres (criminels, civiles ...). Possibilité de réunir toutes les chambres en une assemblée plénière pour rendre une décision.

CCConst est la seule juridiction qui impose aux autres juridictions ses décisions. Art 62 « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »

Les autres juridictions ce sont des arrêts relatifs de chose jugée alors que pour le CConst ce sont des arrêts absolus de chose jugée.

Savoir si le juge peut créer du droit il sil doit seulement l'appliquer. Ceux qui sont contres ont pour argument la séparation des pouvoirs. C'est au parlement de créer le droit. Ce qui se combine avec l'idée que c'est au parlement de faire la loi c'est que les élus sont les seuls légitimes pour faire du droit car ils sont élus par le peuple.

Quand la Cour suprême crée du nouveau droit. Certains ont dit que cela portait atteinte à la démocratie.

S'appuie sur le droit en vigueur. Car le droit dans l'Art 5 du CC « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » qui interdit au juge de créer du droit. (on appel cela des arrêts de règlements). Les juges sont la pour trancher des litiges et appliquer la loi, ils ne sont pas la pour créer du droit.

Ceux qui sont pour que le juge crée du droit ce sont les auteurs des théories réalistes. Il mettent en évidence que l'interprétation est inévitable et quelle est créatrice de droit. Dans les positions les plus extrêmes, on peut dire que les textes deviennent des normes contraignantes qu'avec l'interprétation du juge.

Herbert Hart : fait une théorie sur le fait que le langage est une texture ouverte.

En matière de droits fondamentaux les juges sont allés beaucoup plus loin dans l'interprétation des textes.

Les réserves d'interprétations. Les juges peuvent poser une réserve d'interprétation voir même ajouter au texte.

Sur certains droits communs aux états. Les juges ont des interprétations très différentes.

- En France on a une vision formelle de la normalité. La loi est appliquée de même manière pour tous. Cela sanctionne les discriminations directes.
- Alors qu'au Canada, la jurisprudence va beaucoup plus loin dans l'interprétation de l'égalité. Elle va chercher à rétablir au sein de la société une égalité. Elle va donc sanctionner les discriminations directes et indirectes. La cour canadienne va développer « L'obligation de l'accommodement raisonnable ». La norme n'est pas discriminatoire, mais elle va créer un effet discriminatoire, il faut donc que celui qui applique la loi fasse une interprétation.

Arrêt de 1985 Cour suprême Canadienne, arrêt O'Malley, une employée dans un magasin de prêt à porter qui va se convertir à l'église adventiste du septième jour. Sa nouvelle religion lui interdit de travailler le samedi. La requérante va devant la Cour pour mettre en évidence que son emploi du temps compromet ses croyances religieuses. L'employeur refuse de changer son emploi du temps.

D'un point de vue formel en France cette plainte n'aurait pas lieu. Sauf qu'au Canada la Cour va poser l'obligation de faire un accommodement raisonnable, ce qui implique que l'employeur va devoir modifier l'emploi du temps de son employée.

Autre argument avancé est celui du déni de justice. Le juge a l'obligation de rendre une décision lorsqu'il est saisi. Art 4 CC « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». On admet que lors des vides juridiques les juges peuvent créer du droit pour rendre une décision.

Aujourd'hui la doctrine est plutôt favorable au fait de reconnaître la jurisprudence comme une source informelle du droit. Il faut réussir à délimiter la limite où le juge peut créer du droit. On reconnaît que le juge peut créer du droit, cependant ces derniers doivent s'auto-limiter, et doivent rechercher le fait d'être le plus respectueux du texte.

Le CConst va parfois rajouter des droits et libertés. Il crée donc du droit. Mais très souvent lorsqu'il contrôle les lois il va s'auto-limiter en disant qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement. Il est contraint politiquement.

Dans les pays du Common-Law la jurisprudence est une source du droit. Idée que les juges sont contraints de respecter la règle du précédent. Cependant la jurisprudence ne peut pas être figée.

2-2-3) L'évolution de la jurisprudence

C'est la question des revirements de jurisprudences. Les juridictions reviendraient sur les interprétations constantes pour donner une nouvelle interprétation. Les juges ont tendance à éviter les revirements de jurisprudence. Car cela peut porter atteinte à la sécurité juridique.

George Ripert, dans son ouvrage *les forces créatrices du droit*, il considère qu'il est plus difficile de changer une jurisprudence établie que de changer la loi. Volonté des juges d'avoir une stabilité de la jurisprudence et volonté de complexifier les revirements de jurisprudence. Nécessairement la jurisprudence va évoluer, cela peut résulter de plusieurs facteurs :

- Modification du texte, il est logique que la jurisprudence évolue.
- Évolution de la jurisprudence d'autres juridictions, renvoi au dialogue des juges (les juges vont reprendre et s'inspirer des décisions des autres juges). Ex: CEDH, les juges nationaux s'alignent sur les décisions de la CEDH.
- Contexte (social ou économique), les faits peuvent contraindre à une évolution de la jurisprudence.

Ex: CConst, le juge ne peut contrôler qu'une fois la loi. Pour autant on a admis qu'il y avait des changements de circonstances de droits ou de faits. Qui pouvaient amener à réexaminer une loi.

Ex: il y avait déjà eu un contrôle sur les droits de la garde à vue, on a considéré que l'explosion des GAV pouvait amener à réexaminer la Loi.

Ex: 2004 ajout de la Charte de l'environnement, suite à cela on a considéré qu'il y avait un changement de droit, on a donc pu réexaminer certaines lois sur l'environnement.

Les risques des revirements de jurisprudences:

- Création d'une instabilité.
- Création d'injustices, quand les justiciables sont jugés après le revirement.

Principe fondamentale du droit : « **principe de non rétroactivité de la loi** ». On ne rejuge pas les cas précédents. Par contre la jurisprudence est rétroactive. Car à chaque fois le juge va apprécier les faits qui ont déjà eu lieu.

Ex: En 1974, cas d'un médecin qui procède à un accouchement difficile qui se passe mal. Il préconise un accouchement sans césarienne, à l'époque le médecin n'est pas obligé de prévenir la patiente des risques. L'enfant née avec des séquelles. En 1998, revirement de jurisprudence, qui va obliger le médecin à informer la patiente des risques. Une fois que l'enfant atteint la majorité. L'enfant attaque le médecin en justice sur le fondement de la nouvelle jurisprudence. En Appel le médecin n'est pas condamné. En considérant qu'au moment des faits aucune obligation n'était nécessaire au médecin. Mais dans un arrêt du 9 octobre 2001, la Cour de cassation va considérer que : « l'interprétation jurisprudentielle d'une norme à un moment donné ne peut-être différente selon l'époque des faits considérées et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ». Le médecin est condamné pour des faits de 1974 avec une jurisprudence qui date de 1998.

Les juges acceptent de faire des modulations dans le temps des revirements de jurisprudence. Il ne va pas appliquer le principe de rétroactivité. Il applique la nouvelle jurisprudence uniquement aux situations postérieures du revirement.

Conseil d'état dans un arrêt du 16 juillet 2007 considère qu'une nouvelle jurisprudence ne doit pas s'appliquer immédiatement si cela bouleverserait trop la sécurité juridique.

Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2016, cette dernière a considéré que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients, qu'il soit fait exception de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher au cas par cas s'il existe entre les avantages attachés et les inconvénients une disproportion manifeste.

Cette modulation des effets dans le temps, pour quelle soit plus répandue, il faudrait qu'il y ait un texte qui la prévoit.

Art 62 qui prévoit que le CConstitution peut moduler les effets dans le temps des décisions. Il peut rapporter dans l'avenir le moment où la décision devient contraignante.

De manière générale il y a une stabilité de la jurisprudence. Mais celle-ci doit parfois évoluer pour s'adapter aux évolutions des faits ou du droit, dans cette hypothèse le revirement de jurisprudence est nécessaire avec le risque que ce soit source d'injustice. Car la jurisprudence est rétroactive

2-2-4) Les limites de la jurisprudence

Il y en a deux:

- **Contrainte textuelle.** Le juge doit se référer au texte. Malgré ses libertés d'interprétation il doit se référer au texte. De plus il doit avancer des arguments juridiques. Il ne peut pas se prévaloir de créer du droit. Il n'a pas de pouvoir de décision politique.
- **Le pouvoir politique a le dernier mot.** Si le pouvoir politique n'est pas d'accord avec la jurisprudence il peut passer outre grâce à la modification du texte par le Parlement.

Il y a eu la discrimination positive homme/femme pour les élections ou le CConstitution à décider que cela était inconstitutionnel. On a donc changé la constitution grâce au parlement.

Donc le pouvoir politique est supérieur au pouvoir du juge. Cependant ce pouvoir est limité car complexe. George Vedel disait : « Le CConstitution dispose de la gomme et par le crayon ».

On considère la jurisprudence comme essentielle. Car on ne conçoit pas de système juridique sans interprétation du droit pour autant il y a toujours des critiques sur le pouvoir créateur des juges. Idée du gouvernement des juges: des juges non élus créent du droit.

Création de la jurisprudence peut se faire grâce à la répétition mais elle se fait principalement par grâce au système hiérarchique des juridictions. Qui créent des jurisprudences constantes. Le but est d'uniformiser l'application du droit pour assurer la sécurité juridique. Le juge ne crée pas du droit à partir de rien il doit s'en tenir aux textes.

2-3) Les principes généraux du droit

Ce sont des principes disparates et différents selon les branches du droit. Dans certains cas ils auront une portée morale, dans d'autres ils seront purement techniques.

Des règles admises par la jurisprudence comme s'imposant à l'administration et à ses rapports avec les particuliers même sans texte, et ayant une valeur égale à celle de la loi de sorte que celle-ci peut y déroger et que au contraire l'administration et le pouv réglementaire doivent respecter.

Similitude avec la coutume « sans texte ». Ce sont des principes reconnus par le juge. Avec l'idée que ces principes peuvent poser des limites que doit respecter l'administration. Il y a différents niveaux de principes généraux du droit.

Il faut savoir si ces principes préexistent dans le droit et donc le juge ne fait que les découvrir? Ou est-ce que c'est le juge qui les crée.

2-3-1) Ces principes généraux existants dans plusieurs branches du droit

On les retrouve dans tous les niveaux. Parfois dans les textes il y a des références qui sont faites à ces principes.

• Droit international.

Selon l'Art 38 du statut de la Cour internationale de Justice parmi les différentes sources du droit invocable et applicables devant elles on y retrouve les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. Ce sont des principes communs (pays occidentaux). Un des principes que l'on est sûr de retrouver et la règle *pacta sunt servanda* (Les conventions doivent être respectées) les états sont tenus de respecter les engagements pris. Il ne peuvent pas se prévaloir de en plus se tenir à leurs engagements peut importe les événements internes du pays.

• Droit constitutionnel.

Les principes sont retrouvés dans les PFRLR. Il est fait référence dans le préambule de la constitution de 1946. C'est le juge (CConst) qui va dégager les principes. C'est le CConst qui va reconnaître un nouveau principe en lui accordant une valeur constitutionnelle. Le premier cas étant la décision de « liberté d'association » de 1971. Cette décision est très critiquée car ce dernier reconnaît une valeur constitutionnelle au préambule. Dans ce préambule il y a la référence aux PFRLR. En 1990 il va donner des critères pour reconnaître des nouveaux principes.

Critères :

- Il faut que ce principe soit issu dans texte législatif antérieur à 1946. (Le principe doit-être inclu dans la loi).
- Il faut que la loi prise pour ce principe ait été prise par un régime républicain (exclu le régime de vichy...).
- Ayant fait l'objet d'une application continue.
- Que ce principe ait été consacré comme principe général et non-contingent.
- Les PFRLR doit présenter une importance suffisante, doit concerner les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics. (critère matériel)

• Droit administratif.

On retrouve les principes généraux dans les jurisprudences du Conseil d'Etat. Il s'en servait bien avant le CConst. Dans un arrêt du 22 mai 1946 « arrêt MAILLON » le conseil d'état s'est fondé sur « les principes applicables même en l'absence d'un texte ». Il a reconnu l'existence d'un principe du respect au droit de La Défense.

Dans un arrêt du 9 mars 1951 « arrêt société des concerts du conservatoire » dans cet arrêt le CE consacre « le principe d'égalité des usagers devant le service public ».

Ces principes généraux sont retrouvés en droit privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En dehors des textes et se retrouvent dans les différentes matières du droit privé.

On retrouve des principes généraux dans toutes les matières.

2-3-2) Portée des principes généraux du droit

Cela dépend du juge qui consacre ces principes. Devant le CE, les auteurs s'accordent pour dire que les principes généraux ont une valeur supérieure au domaine réglementaire. Car ce sont des principes qui sont utilisées par les juges pour contrôler les actes réglementaires. Cela signifie que l'on peut faire prévaloir ces principes sur des actes administratifs et donc logiquement une valeur supérieure au domaine réglementaire.

Arrêt CE du 26 juin 1959 « arrêt syndicat général des ingénieurs-conseils ».

La question de valeur législative des principes généraux fait débat. Pr René Chapus dit que « ces principes ont une valeur infra-législatif et supra-général ». Cela signifie qu'ils sont entre deux niveaux. Ils sont entre les règles et les lois. Il dit « le juge administratif est soumis à la loi dont il ne peut apprécier la validité, il est au contraire en mesure d'invalider les actes ».

des titulaires du pouvoir réglementaire ».

La vision de René Chapus néglige totalement le pouvoir créatif du juge. Il se focalise sur la loi et reste dans la tradition légicentriste.

Les auteurs réalistes mettent en avant le fait que si la loi était capable de tout régir, il n'y aurait pas besoin de ces principes.

Du côté du CConst les PFRLR, ces derniers ont valeur constitutionnel. Car c'est à partir de ces principes qu'il contrôle et censure les lois. Les principes sont supérieurs aux lois.

Les principes peuvent intervenir dans trois hypothèses:

- Intervention *secundum legem*, c'est-à-dire après la loi. Les principes coexistent avec la loi et que c'est la loi qui y fait référence.
- Intervention pour compléter ou pallier aux insuffisances de la loi. Cas de vide juridique. Un des principes qui s'impose au juge est l'impossibilité du déni de justice. Principe *praeter legem*
- Principe général du droit irait à l'encontre de la loi. La Cour de cassation accepte que certains bien considérés comme des souvenirs de familles échappent aux règles de successions. Principe *contra legem*.

Principes généraux du droit sont consacrés par les juges.

Ont la particularité d'avoir des effets juridiques contraignants.

2-4) La doctrine

L'interprétation authentique est l'interprétation du juge, elle a un effet contraignant alors que l'interprétation doctrinale n'a pas d'effet juridique contraignant.

L'opinion communément professée par ceux qui enseignent le droit ou même ceux qui sans enseigner écrivent sur le droit.

2-4-1) Quelle valeur accorder à la doctrine en temps que source du droit

Il peut y avoir une influence de la doctrine sur les producteurs du droit. Cette influence se matérialise quand les créateurs et les interprètes de droit y font référence.

En Rome antique ce que l'on appelait les juristeconsults avaient un pouvoir d'influence important car c'est ces derniers qui lorsqu'il n'y avait pas de droit pour trancher un litige on faisait appel à eux pour proposer une solution qui pouvait être acceptée par le juge.

Dans les grands textes de la Rome antique, il y avait le Codex, recueil des lois impériales, et les Digeste, un condensé de la doctrine. Les opinions de la doctrine de l'époque avaient une certaine importance.

Les théories du droit naturel ont façonné la manière moderne de concevoir le droit en mettant en avant certaines valeurs. La conception moderne du droit naturel qui est centrée sur l'individu et la protection des droits et libertés individuelles sont la base de notre modèle de droit moderne.

Les théories de séparation des pouvoirs, c'est la doctrine qui a permis de façonner notre droit contemporain.

La doctrine va beaucoup dépendre de la volonté des auteurs et de ce qu'ils recherchent. Certains recherchent une influence sur le droit, tandis que d'autres pas du tout.

Selon les théories positivistes, l'ambition des universitaires est d'expliquer le fonctionnement du droit. Ils doivent rester dans le descriptif.

Cette vision très descriptive de la doctrine a été critiquée par plusieurs auteurs et notamment Philippe Malaurie. Dans son ouvrage d'introduction à l'étude du droit, il écrivait que « la doctrine se renie si, comme souvent aujourd'hui, elle n'est que technique en s'affichant positiviste, liant le droit à l'Etat et le détachant de tout fondement moral, politique ou économique pour en faire une science pure comme une autre science ». Cette critique est adressée au normativisme de Kelsen.

Pour autant, même si l'ambition des auteurs est de faire quelque chose de neutre et purement descriptif, leur travail exercera tout de même une influence. Si l'on se rapporte à ces théories, les auteurs donnent une vision du droit. Plusieurs auteurs disent que la doctrine doit prendre conscience de cette influence. C'est notamment le cas du professeur Goubeaux, qui considère que la doctrine est importante dans la mesure où « les auteurs réfléchissent sur le droit et formulent des énoncés et des propositions juridiques. Ils ont une autorité pour dire ce qui est juste et donc poser du droit même si ce droit n'est pas imposé ».

2-4-2) De quelle manière la direction peut influencer la production du droit

Que ce soit dans leurs recherches ou dans leurs publications (thèses, articles, colloques, etc.), ils vont avoir une vision qui peut conduire à changer le droit positif. Plusieurs auteurs vont chercher à remplacer les théories dominantes. Par exemple, les théories positivistes ont été créées en réaction au droit naturel. Cela peut être d'un point de vue purement moral, technique ou critique.

Les théories du droit global sont défendues notamment par les chercheurs de l'institut *Max Planck*. Elles commencent à gagner du terrain car elles cherchent à mettre en évidence que se centrer sur l'Etat et les normes qu'il produit ne décrit pas la réalité actuelle. L'Etat n'est pas le seul acteur de la production des normes. Elles vont s'intéresser aux normes produites par les acteurs privés (entreprises par exemple). Le droit global veut mettre en évidence que le droit n'est plus limité aux frontières des Etats et que ceux-ci perdent petit à petit leur emprise sur la production du droit.

Les théories du pluralisme juridique cherchent à mettre en évidence la variété des modes de production des règles de droit. Elles suivent le même chemin que le droit global mais mettent en évidence la complexité des modes de production des normes. Pour la France, ils mettent en avant le fait que pleins de systèmes de production des normes se superposent.

Toutes les théories doctrinales sont la base de nos systèmes juridiques et institutionnels. Le droit positif est issu de la doctrine. L'interprétation est également façonnée par la doctrine (école de l'exégèse).

De plus, aujourd'hui, les acteurs de la doctrine s'intéressent de plus en plus à ce qu'il se passe à l'étranger et cela influe le droit français.

La doctrine qui commente exerce une influence beaucoup plus concrète et directe sur le droit positif. Le commentaire de jurisprudence exerce une influence très pragmatique, notamment sur le travail des avocats. Ils doivent interpréter la jurisprudence et l'invoquer devant le juge.

Entre le dépôt et le travail à l'AN, il y a des commissions qui font parfois appel à des spécialistes. Ces spécialistes sont souvent des universitaires. En tant que spécialiste, ils ont un pouvoir d'influence.

Le juge utilise aussi la doctrine. Elle influence l'interprétation authentique du droit. En France c'est assez implicite, mais certaines juridictions comme la Cour Suprême canadienne sont beaucoup plus explicites et détaillent comment l'interprétation authentique qu'ils font du droit se base sur des interprétations doctrinales.

Des universitaires envoient au CConst leurs avis sur la décision à rendre. Depuis 2017, le CConst publie ces avis sur son site internet. Jusque là il y avait une critique de l'approche opaque qualifiée de lobbying des universitaires. On parle à présent de contribution extérieure.

De plus, beaucoup d'universitaires ont été nommés juges du CConst et ont donc pu influencer directement le droit.

L'influence première de la doctrine se retrouve dans l'enseignement. C'est à travers les discours sur le droit dispensés par les enseignants que la vision du droit des étudiants est façonnée.